

一、金融借款合同纠纷

1. 贷款人对调整借款利率的格式条款负有提示说明义务 1
——某银行诉潘某、李某金融借款合同案
2. 贷款人宣布贷款提前到期条款的效力认定5
——中国某银行股份有限公司威海文登支行诉何某等金融借款合同案
3. 担保人的追偿权相对于主债权具有劣后性 10
——某房地产开发有限公司诉侯某金融借款合同案
4. 抵押权设定之日开发商的阶段性担保责任即告完成 14
—— 某银行诉张某、某置业公司金融借款合同案
5. 分期手续费实为利息，预收部分应当抵扣借款本金 18
——某银行顺德某支行诉甘某金融借款合同案
6. 借款人以银行未对勾选的借款利率条款、罚息和复利条款进行提示说明为由，主张以上条款不成为合同内容的，依法不予支持 22
——黄某某诉某银行金融借款合同案
7. 金融机构已取得按揭房屋抵押权的情况下开发商的阶段性担保责任应当免除26
——某银行新会支行诉某房地产公司等金融借款合同案

2 中国法院2025年度案例·金融纠纷

8. 金融机构善意取得抵押权中“善意”的认定规则30
——某银行诉杨某金融借款合同案
9. 金融借款中配偶方“共债共签”意思表示的认定 37
——甲银行股份有限公司诉炊某甲等金融借款合同案

二、银行卡纠纷

10. 持卡人服刑期间其亲属的用卡行为不属于盗刷行为.....41
——吴某某诉某银行信用卡中心等信用卡案
11. 持卡人主张银行卡被网络盗刷应当就盗刷事实的存在尽到初步
的举证责任..... 45
——周某某诉某银行借记卡案
12. 电信诈骗中银行责任的认定 48
——陈某某诉某银行某分行、某银行某支行借记卡案
13. 金融机构在电信诈骗导致的网络盗刷交易中的责任认定53
——李某诉某银行借记卡案
14. 金融交易合同中单方变更条款的效力认定规则.....57
——郝某某诉某银行股份有限公司、某银行股份有限公司信用卡中心信
用卡案
15. 跨境消费中信用卡预授权后超额结算的司法审查61
——余某某诉某银行信用卡中心信用卡案
16. 网络盗刷银行卡案件的举证责任分配67
——王某某诉某银行某支行借记卡案
17. 为避税提起虚假诉讼，法院应不许撤诉并驳回诉请和予以罚款 73
——孙某某诉某银行小关支行银行卡案

18. 信用卡被盗刷的法律适用及刑事退赃与民事赔偿之间的衔接	77
——宋某某诉某银行股份有限公司信用卡中心信用卡案	
19. 以第三人实施欺诈为由主张撤销合同的司法审查要点	83
——秦某诉某银行北京分行信用卡案	
20. 银行卡伪卡盗刷案件中发卡行责任的认定与处理	87
——李某某诉某银行银行卡案	

三、融资租赁合同纠纷

21. 融资租赁出租人自行收回并处置租赁物的，因可归责于出租人 事由造成租赁物价值贬损，出租人应承担不利后果	91
——某融资租赁公司诉钟某某融资租赁合同案	
22. 融资租赁公司从事融资担保的合同效力	95
——某融资租赁公司诉翁某某、某物流公司追偿权案	
23. 融资租赁合同关系被否定后附属抵押合同的效力认定	99
——某融资租赁公司诉某进出口公司等破产债权确认案	
24. 融资租赁合同纠纷中承租人未按约定方式还款、改装车辆构成 违约	104
——罗某诉某融资租赁公司融资租赁合同案	
25. 融资租赁出租人收回租赁物后的权利限制	109
——某融资租赁公司诉陈某某融资租赁合同案	
26. 售后回租融资租赁关系中名义所有权人有义务协助办理抵押权 注销登记	113
——刘某诉重庆某租赁公司融资租赁合同案	

四、委托理财合同纠纷

27. 民间委托理财合同的效力认定 119
——刘某诉孙某民间委托理财合同案
28. 金融机构适当性义务责任减免的认定 123
——卓某某诉某银行朝天路支行金融委托理财合同案
29. 私募基金投资顾问“名顾实管”，应对基金发行管理人负连带赔偿责任 130
——李某某诉某投资公司、某资产管理公司金融委托理财合同案

五、证券纠纷

30. 保荐人在出具保荐意见后解除保荐协议的审查标准 135
——某集团公司诉某证券公司证券上市保荐合同案
31. 基金管理人未尽适当性义务的认定标准及责任承担 139
——王某诉某投资基金公司证券投资基金交易案
32. 融资融券交易投资人开具两融账户借予他人使用责任承担及损失认定 143
——某证券公司诉万某融资融券交易案
33. 上市公司并购重组财务顾问的独立性应受到保护 148
——酒业公司诉证券公司证券投资咨询案
34. 审计机构因严重过失引发虚假陈述侵权可承担比例连带责任 152
——某基金公司诉某会计师事务所证券虚假陈述责任案
35. 特殊情形下证券虚假陈述交易因果关系的认定 159
——甲证券股份有限公司诉乙股份有限公司等证券虚假陈述责任案

36. 证券虚假陈述责任纠纷中损失核定方法的选择	163
—— 顾某某等投资人诉某科技股份有限公司证券虚假陈述责任案	

六、信托纠纷

37.“ 非典型主动管理型信托”中受托管理人的义务范围及责任认定	168
—— 某农村商业银行股份有限公司诉某信托股份有限公司营业信托案	
38.“ 事务管理类信托”中受托人的义务范围及责任认定	175
——某科技公司诉某信托公司营业信托案	
39. 信托财产现状分配的约定不构成对分配债权声明数额真实性的免责	181
——程某某诉某某信托公司营业信托案	
40. 资管产品未完成清算情形下投资者损失的认定	185
——甲银行诉甲证券公司营业信托案	

七、保险纠纷

41. 保险代理合同中推荐人签署的保证条款的效力认定	190
——某保险公司诉姜某某、朱某某保险代理合同案	
42. 雇主责任险中雇员的认定不以劳动关系为限	195
——某建筑劳务公司诉某保险公司保险合同案	
43. 设置赔付年龄上限条款的效力认定	200
——某物业公司诉某保险公司保险合同案	
44. 外卖从业人员保险合同中驾驶证逾期的保险责任认定	205
——余某甲等诉某保险公司意外伤害保险合同案	

八、票 据 纠 纷

45. 持票人在票据到期日前提示付款且票据状态持续为“提示付款待签收”的，该提示付款行为具有到期日提示付款的效力	210
—— 某贸易公司诉设计院福建分公司等票据追索权案	
46. 持票人在规定的时效期间内行使票据追索权适用诉讼时效中断的规定	215
—— 郑州某某商贸公司诉广西某某防水工程公司等票据追索权案	
47. 电子商业汇票期前提示付款的效力认定	219
—— 武汉某公司诉佛山某公司等票据追索权案	
48. 电子商业汇票线下追索效力的司法认定	223
—— 节能公司诉装饰公司等票据追索权案	
49. 电子商业汇票再追索时票据权利客体是否会基于后手之间的债务减免行为产生限缩的法律认定	232
—— 建工公司诉旅游公司票据追索权案	
50. 汇票被追索人行使再追索权的客体范围是否包含前案诉讼费用	238
—— 福建某某建设工程有限公司诉福州某房地产开发有限公司、福建省某某建设工程有限公司票据追索权案	
51.“ 间接交易关系”作为票据法上原因之债的证明和审查	247
—— 甲公司诉乙公司等票据追索权案	
52. 票据具有独立性，现有证据无法证明票据前手的负责人涉嫌犯罪行为与案涉票据行为系同一事实的，人民法院应当对该案予以受理	252
—— 劳务公司诉旅游公司等票据追索权案	

53. 票据追索对象为一人公司时人格否认的扩张与限制	257
—— 商贸公司诉某路桥公司等票据案	
54. 票据追索权权利时效的起算点应以第一次被拒付付款之日为准	261
—— 保定某汽贸公司诉邯郸某房地产公司等票据追索权案	
55. 票据追索受债权转让合同约定之票据内在无因性限制的司法判定	267
—— 某信托公司诉某装饰工程公司等票据追索权案	
56. 票据追索因民间贴现无真实的交易关系和债权债务关系, 法院依法判驳	276
—— 某装饰中心诉建工公司票据追索权案	
57. 前案诉讼费用和保全费用不应当认定为票据再追索权的范围	281
—— 混凝土公司诉建设公司、置业公司票据追索权案	
58. 一人公司年度审计报告对公司与股东财产独立具有证明力及其审查	285
—— 装饰公司诉置业公司、地产公司票据付款请求权案	
59. 汇票保证不适用民法典关于保证期间的规定	289
—— 某银行股份有限公司北京分行诉某房地产集团有限公司等金融借款合同纠纷案	

九、其他

60. 非典型担保下的物权法定原则及破产案件公平受偿	294
—— 小额贷款公司诉房地产公司普通破产债权确认案	
61. 保险人开具的履约保函是否构成独立保函的认定标准	303
—— 某城乡建设局诉某保险公司独立保函案	

8 中国法院2025年度案例·金融纠纷

- 62.“ 池保理”模式下部分应收账款为虚构的法律关系性质认定 308
——融资租赁公司诉广告公司等保理合同案
63. 典当纠纷中未明示中介人身份的处理 312
——某典当行诉步某某、解某某典当案
64. 独立保函欺诈的司法认定 316
——某科技公司诉某材料公司独立保函欺诈案
65. 独立保函欺诈中受益人明知其没有付款请求权仍滥用该权利的
认定 321
——电力公司诉火电公司独立保函欺诈案
66. 有追索权保理中应收账款债权人和债务人的责任关系认定及诉
讼程序实现 325
——金融保理公司诉供电公司等保理合同案
67. 员工股票期权纠纷中“行权”的法律效果 329
——代某诉某控股公司等合同案

一、金融借款合同纠纷

1

贷款人对调整借款利率的格式条款负有提示说明义务

—— 某银行诉潘某、李某金融借款合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省佛山市顺德区人民法院(2023)粤0606民初26168号民事判决书

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人

原告：某银行

被告：潘某、李某

【基本案情】

某银行与潘某、李某签订金融借款合同。关于借款利率，合同中有三处约定：一是在第二页，约定初始借款利率为年利率6.9%；二是在第三页，约定借款人未依约偿还本金的，按约定的借款利率加收50%的罚息，对未依约支付的利息按罚息利率计收复利；三是在第十八页，约定借款人未依约偿还本金及利息费任一项，且连续逾期超过十五个自然日的，借款利率调整为自发放之日起实行合同成立时一年贷款市场报价利率的四倍的固定利率，相应罚息等一并调

整。此外，合同对违约解除、抵押担保、实现债权的费用承担等方面也进行了约定。合同签订生效后，原告依约向两被告发放贷款。两被告收到贷款后未依约履行合同义务，原告遂提起诉讼，要求两被告立即偿还借款本金、对未付本金和利息按一年贷款市场报价利率的四倍再上浮50%的利率分别计收的罚息和复利，以及律师费、诉讼费等，并主张对抵押物处置款享有优先受偿权。

【案件焦点】

潘某、李某的逾期利率标准如何确定。

【法院裁判要旨】①

广东省佛山市顺德区人民法院经审理认为：利率条款是借款合同的核心条款，明确贷款人负有全面披露借款利率的义务，是确保借款合同符合借款人真实意思表示的必然要求。本案中，贷款人主张通过适用调整利率条款，使借款人负担的逾期利率从年利率6.9%先调整为年利率15.4%，再上浮50%加收罚息，借款人实际承担的逾期利率为年利率23.10%，为期内借款利率的三倍有余，同时将借款人承担违约责任的时间溯及贷款发放之日，既使借款人难以对违约后果产生合理预期，又加重了借款人的负担。案涉调整利率条款位于合同第十八页，未予加粗提示，该条款无论是在其自身的显著性方面，还是在与第二页、第三页借款利率条款、逾期利率条款的整体性、连贯性方面，均无法达到足以引起借款人知晓的要求。因某银行未明确提示说明该条款导致借款人没有注意或理解违约时应负担的实际利率，应视为双方未就借款利率调整条款达成合意，该调整利率条款不成为借款合同的内容，故对于某银行主张的逾期利率，仅在合同记载的年利率6.9%上浮50%即年利率10.35%的范围内予以支持。据此，广东省佛山市顺德区人民法院判决如下：

一、潘某、李某应于判决发生法律效力之日起十日内向原告某银行支付借款本金715625元、利息12207.37元及相应的罚息、复利（罚息暂计至2023年

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

9月5日为109660.59元，此后以尚欠本金为基数按年利率10.35%计至实际支付之日止；复利暂计至2023年9月5日为1950.63元，此后以尚欠利息为基数按年利率10.35%计至实际支付之日止）；

二、潘某、李某应于判决发生法律效力之日起十日内向原告某银行支付律师费6000元；

三、某银行就上述第一项、第二项判决确定的债权对被告潘某、李某的某房产折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；

四、驳回某银行的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】①

金融借款合同中，利率条款是核心给付条款，金融机构根据借款人的信用风险进行差别定价，借款人在不满意利率条款时不予缔约，不存在双方经济能力差异导致的“强制缔约”，因而在通常情况下，当事人应受合同条款约束。但近年来，随着金融借贷业务广泛开展，个别银行为了扩大业务规模，以名义上的较低利率吸引客户，实际上通过设置多个借款利率条款迂回收取高利率息费，金融消费者签订合同时，如不加注意，往往很难察觉。本案的“调整借款利率”条款便是其中一种典型形式。

一、“调整借款利率”条款的特点

“调整借款利率”条款是指借款人在发生特定违约情形时，贷款人有权将合同原定的借款利率予以调高并溯及贷款发放之日，借款人需按调整后的利率标准再上浮一定比例支付期内利息和逾期罚息。合同条款。“调整借款利率”条款具有以下特点：一是非合意性，有关内容系由贷款人单方拟定，未经双方协商确定。二是非常规性，按照《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》的规定，罚息利率通常为借款合同载明的贷款利率水平上加收30%—

①本书【法官后语】对此类法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

50%,而适用调整借款利率条款之后,借款人需承担的罚息利率远高于行业通常标准,借款人难以产生合理预期。三是非显著性。贷款人通过定义多个利率名称来掩饰实际可能发生的高利率息费,使借款人难以认识到其负担的真实借款成本。综上,“调整借款利率”条款属于与借款人有重大利害关系的格式条款,确有必要适用格式条款的有关规则予以审查。

二、贷款人对“调整借款利率”条款负有提示说明义务的法律基础

贷款人对于借款利率的提示说明义务在现行法上虽无直接规定,但具备充分的法律基础。消费者权益保护法第二十八条规定了商家告知服务价款、费用的义务,民法典第四百九十六条第二款规定了提供格式条款一方的提示说明义务。除此之外,《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》第三条、《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》第十六条均明确要求金融机构以通俗易懂的语言,及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露可能影响其决策的信息,对利率、费用、违约金等与金融消费者切身利益相关的重要信息进行解释说明,从而保障金融消费者的知情权。上述规定反映,要求贷款人准确披露各利率条款是正当的。通过对全部利率条款的披露,将全面展现不同情形下借款人的真正利息负担,既有利于确保债务人的真实意思表示不受侵蚀、避免债务人“过度负债”,又有助于构建竞争有序、信息透明的市场环境。

三、在金融借款合同纠纷中适用格式条款规则应考虑的因素

格式条款在金融借款合同中被广泛运用,具有简化业务程序、降低缔约成本、提高交易活动效率等功能。法院在审查涉金融借款合同纠纷格式条款效力争议时,既要尊重格式条款所体现的意思自治,又要特别保护金融消费者以维护实质公平。具体而言,需重点考虑以下几方面因素:一是审查诉争条款是否为格式条款,判断是否适用格式条款规则。通常而言,关于借款利率、借款期限等核心给付条款是借款人与贷款人订立合同的主要考量因素,该内容系双方协商而定,不应认定为格式条款;仅在贷款人单方拟定的、不具有协商性的条款,如对特殊概念的重要定义解释条款等,方能有适用空间。二是审查双方合

意度，判断格式条款是否订入合同。如贷款人已履行提示说明义务，可视为双方形成合意；如贷款人未履行提示说明义务，则进一步分析诉争条款的效力对合同整体成立与生效的影响程度，如影响程度轻微，则可订入合同。相反，与借款人有重大利害关系的格式条款未经提示说明不订入合同。三是审查权利义务均衡度，判断格式条款有无效力。格式条款的内容控制标准，需要从双方交涉力量、相对人被侵害利益类型、限制相对人的合同权利是否具有合理性等方面进行考量，例如，罚息、复利条款约定的逾期利率较高，超过了法律规定的上限，属于民法典第四百九十七条规定的格式条款无效的情形，法院应依法认定相应的格式条款无效，对利率计算标准予以调整，使之兼顾保护金融消费者及违约惩罚性的原则。

编写人：广东省佛山市顺德区人民法院 黄燕芝 曾乐乐

贷款人宣布贷款提前到期条款的效力认定

—— 中国某银行股份有限公司威海文登支行诉何某等金融借款合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省威海市文登区人民法院(2023)鲁1003 民初410号民事判决书

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人

原告：中国某银行股份有限公司威海文登支行(以下简称某银行文登支行)

被告：何某、王某、某房地产公司

【基本案情】

2016年8月29日，某银行文登支行与何某、王某、某房地产公司签订《个人购房借款/担保合同》，约定何某、王某共同向某银行文登支行贷款481000元用于购买某处房屋，贷款期限240个月。借款人按照按月等额本金还款法（按月计息）偿还贷款本息。借款人自愿选择每月19日为还款日。贷款的担保方式为保证、抵押，某房地产公司为保证人，承担阶段性连带责任保证，保证期间为本合同项下贷款到期之日起两年；贷款人依据合同约定宣布贷款提前到期的，保证期间为贷款提前到期之日起两年。何某、王某以上述房屋进行抵押，双方办理了抵押预告登记。

上述合同第十四条约定，借款人连续三个月或累计六次未按时足额偿还贷款本息的，贷款人可以采取下列一项或多项措施：（1）要求借款人限期纠正违约行为；（2）要求借款人另行提供借款人认可的担保；（3）停止发放本合同及依据贷款人与借款人之间其他合同项下的贷款和其他融资款项，部分或全部取消借款人未提取借款和其他融资款项；（4）宣布本合同和贷款人与借款人之间其他合同项下未偿还的借款和其他融资款项立即到期，要求借款人立即清偿未偿还款项以及所产生的利息、罚息和其他费用；（5）解除本合同；（6）要求借款人赔偿因其违约给贷款人造成的损失；（7）法律法规规定，本合同约定或贷款人认为必要的其他措施。第十七条约定，贷款人为实现本合同项下的债权及担保权利而产生费用，包括但不限于律师费、评估费、拍卖费等由借款人承担。对于贷款人为保障自身利益先行垫付的费用，贷款人有权随时向借款人追偿，并从其垫付之日起计收活期存款利息。

某银行文登支行于合同签订后向何某、王某发放贷款481000元。何某、王某按照合同约定每月偿还贷款。2020年8月19日、9月19日两笔贷款本息未足额清偿，2020年10月19日，何某、王某将此前两个月所欠本息及当月本息一并清偿。2021年3月19日贷款本息未清偿，何某、王某于4月10日偿还了该笔款项。2021年8月19日贷款本息未清偿，何某、王某于8月31日偿还了该笔款项。2022年2月、3月、4月的贷款未按照约定偿还，5月11日何某、

王某偿还部分本息。2022年5月贷款本息未偿还，何某、王某欠付某银行文登支行本金3683.42元，利息2575.7元。2022年6月、7月、8月，何某、王某均于当月16日被划扣还款金额，19日产生一笔新的贷款金额。2022年9月22日，何某、王某还清此前所有积欠的本金及利息。至法庭辩论终结时，何某、王某不存在逾期未偿还的本金、利息、罚息等。

2022年9月28日，某银行文登支行与某律师事务所针对本案在内的28起案件的诉讼事宜签订委托代理合同，约定本案的律师代理费为17218元，同年10月25日某律师事务所出具本案律师费发票，11月14日，某律师事务所收到包含案涉律师费在内的款项。

【案件焦点】

某银行文登支行对何某、王某等轻微并纠正的违约行为，主张有权宣布贷款提前到期，要求借款人提前清偿全部贷款本息及律师费等为实现债权而产生的相关费用是否应当准许。

【法院裁判要旨】

山东省威海市文登区人民法院经审理认为：某银行文登支行与何某、王某、某房地产公司签订的《个人购房借款/担保合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。何某、王某确有合同约定的连续三个月及累计六次未按时足额偿还贷款本息的情形，某银行文登支行有采取要求借款人限期纠正违约行为或宣布本合同款项立即到期，要求借款人立即清偿未偿还款项以及所产生的利息、罚息和其他费用等的权利，但截至2022年9月22日，何某、王某偿还了所有逾期贷款本息，纠正了违约行为，某银行文登支行接受了何某、王某的履行，并未拒绝，亦未提供证据证实此时其已经将要求宣布本合同款项立即到期的意思表示告知了何某、王某，故应视为其已接受何某、王某继续履行合同的请求，在此情况下，某银行文登支行起诉要求何某、王某提前清偿全部贷款本息，本院不予支持。同时，何某、王某在数年间均按照合同约定向某银行文登支行偿还了贷款本息，虽然

在2020年至2023年初存在几笔违约，但金额仅为几千元，数额不大，又都及时进行了清偿，充分表明了何某、王某目前仍具备继续履行合同的意愿和能力，其违约情形尚属轻微，某银行文登支行亦并未遭受损失，不影响合同目的的实现。在此情况下如要求借款合同提前到期，让何某、王某一次性立即偿还30余万元的借款本息，会导致双方当事人权益保护的严重失衡，亦不利于某银行文登支行债权的实现。

2022年9月22日，何某、王某偿还了所有逾期贷款本息，纠正了违约行为，某银行文登支行受偿后，仍于9月28日聘请律师，提起诉讼，由此产生的律师费、诉讼费，不应由何某、王某承担。何某、某房地产公司经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其已经放弃一审中举证、质证的抗辩权利。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第一百四十七条规定，判决如下：

驳回某银行文登支行的全部诉讼请求。

【法官后语】

金融借款合同中普遍存在一旦违约即宣布贷款提前到期的条款约定，分期付款的金融借款合同中通常存在借款人逾期还款达到某种情形下，银行有权宣布合同款项立即到期的约定，本案约定的是连续三个月及累计六次未按时足额偿还，更有甚者约定只要出现一次逾期，银行就有权宣布所有贷款提前到期。宣布贷款提前到期的条款约定，旨在保护银行的资金安全，但宣布贷款提前到期对借款人也有重大影响，故而在司法实践中，对该条款是否具备适用前提应当审慎判断。

一、银行应就宣布贷款提前到期条款向借款人提示说明

《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第一款规定，格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。金融借款合同中违约责任部分的宣布贷款提前到期条款基本上都系固定的，借款人无法协商的格式条款。借款合同往往长达十几页，非法律、金融专业的借款人很难完整阅读合同，往往只知道借款金额、利率、每期还款金额等事项，对于逾期还款达何种程度需要承担何种费用并不一定明确。鉴于银行在订立金融借款合

同时提供格式条款、审查资金发放的优势地位，其应在订立合同时通过字体加粗、增加下画线等方式就宣布贷款提前到期条款进行明确告知。

二、完善宣布贷款提前到期条款约定及银行的通知义务

在分期付款的金融借款合同中，关于宣布贷款提前到期的条款约定的条件较为宽松，以上述案件为例，借款人的贷款期限为240个月，但按合同约定连续三个月及累计六次未按时足额偿还的，银行便有权宣布贷款提前到期，不仅未履行的时间设置较短，未履行的条件也很严苛，未及时、未足额都包含其中且约定不明，借款人在长达二三十年的时间中，收入、资金情况不能有一点“风吹草动”，否则将可能面临提前到期的巨额债务，不利于实现目前提振消费的经济目的。所以银行在设立该条款时应根据贷款金额、贷款时间长短、逾期情况的程度进行区别，分情况制定条款，并设置延期条款，给予适当的延期机会，当借款人出现暂时性的资金困难时可以与银行协商延期。另外，对于出现逾期的借款人，银行应通过电话、短信等方式及时提醒借款人还款或办理延期，对于逾期严重却无还款能力或意愿的，再行通过司法程序解决。

三、司法审查

宣布贷款提前到期虽不以解除合同为前提，但会产生解除合同的实质效果，故审理此类案件时切不可简单地依据合同约定一概而论，一判了之。在审理时可以合同解除的情形为限，综合考量借款人逾期还款的次数、金额、频率、尚欠款项金额、借款人的主观意愿、还款能力等情况，确定是否属于当事人一方迟延履行主要债务，催告后在合理期限内仍未履行或当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的等情形，借款人如果只是轻微违约，虽达到了合同约定的情形，但有偿还的意愿与能力，能及时采取补救措施，不宜支持银行要求合同提前到期，由借款人一次性偿还所有本金、利息及其他费用的主张，避免对银行权利的过度保护而使借款人，特别是因为住房、生产经营等民生问题而进行借贷的借款人的经济状况陷入困境乃至绝境，以及银行贷款难以有效收回的不利局面，以彰显司法的公平与温度。

编写人：山东省威海市文登区人民法院 张新

担保人的追偿权相对于主债权具有劣后性

—— 某房地产开发有限公司诉侯某金融借款合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市江北区人民法院(2023)渝0105民初30356号民事判决书

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人

原告：某房地产开发有限公司(以下简称某房地产公司)

被告：侯某

【基本案情】

2021年2月5日，某农商行(贷款人)与侯某(借款人/抵押人)、某房地产公司(保证人)签订房屋按揭贷款合同，约定某农商行出借侯某96万元用于购买案涉房屋，借款期限为336个月，本合同项下借款担保方式为阶段性保证加抵押，由某房地产公司从借款发放之日起至侯某取得房地产权属证书并办妥抵押登记手续之日止为侯某的借款提供连带责任保证，保证范围包括借款本金、利息、罚息、复利、律师费等，侯某以其所购房屋为借款提供抵押担保。2021年1月31日，侯某与某房地产公司就案涉房屋签订商品房买卖合同，总成交金额1205554元，首付款245554元，剩余房价款96万元由侯某以按揭贷款方式支付，等等。发放贷款后，因侯某未按月足额偿还每期借款本息，故2022年4月29日，某农商行起诉要求侯某、某房地产公司偿还借款本金及利息等。生效判决认定侯某返还某农商行借款本金950111.39元并支付利息、罚

息和复利若干，并判决某房地产公司对侯某的前述债务承担连带清偿责任。2023年4月24日，法院在执行程序中扣划某房地产公司银行存款100万元，主债仍未清偿完毕。某房地产公司要求侯某偿还代偿款未果，遂诉至法院，要求侯某支付代偿款100万元及从代偿之日起按 LPR 计算的资金占用利息和律师费。

【案件焦点】

担保人代偿后的追偿权相对于主债权是否具有劣后性。

【法院裁判要旨】

重庆市江北区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第七百条规定，保证人承担保证责任后，除当事人另有约定外，有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿，享有债权人对债务人的权利，但是不得损害债权人的利益。案涉房屋的按揭贷款合同经本院判决确认某房地产公司为侯某购买案涉房屋的贷款承担阶段性担保责任，并经本院扣划执行某房地产公司已履行款项100万元用于偿还某农商行的欠付贷款本息。某房地产公司承担了部分担保责任后，主张侯某向其偿还代偿款100万元及自2023年4月24日起按 LPR 计算的资金占用利息并支付律师费的请求，符合双方约定和法律规定，本院予以支持。某房地产公司被某农商行实现部分担保债权后，享有向主债务人追偿的权利，但因主债权尚未清偿完毕，依据民法典第七百条之规定保证人行使追偿权时不得损害债权人的利益的规定，本院认定主债务人在案涉主债权清偿完毕后，才能向某房地产公司进行清偿，除非主债权人同意。综上，依照民法典第七百条等之规定，判决如下：

一、被告侯某于本判决生效之日起十日内向原告某房地产公司偿还代偿款100万元，并支付以代偿款100万元为基数，自2023年4月24日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至还清之日止的资金占用利息（主债权尚未清偿完毕之前，侯某不得向某房地产公司清偿前述款项，除非主债权人同意）；

二、被告侯某于本判决生效之日起十日内向原告某房地产公司赔偿律师费4500元。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

一、保证人行使追偿权的条件

保证人要行使追偿权，应当具备以下条件：一是保证人已向债权人承担了全部或者部分保证责任；二是保证人履行了主债务人的全部或者部分债务，从而导致债务人的债务全部消灭或者部分消灭；三是保证人代主债务人履行全部或者部分义务后，从而追偿权尚未消灭；四是保证人的追偿权的范围只能在其承担保证责任的范围内，即使实际清偿额大于主债权，保证人也只能在主债权的范围内行使追偿权；五是保证人履行保证义务过程中不存在因故意或者过失未能行使主债务人的抗辩权而造成不应有的履行或者超过应有范围的履行等。

二、保证人代偿后是否享有完全债权代位权

民法典第五百四十七条规定：“债权人转让债权的，受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外。受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记手续或者未转移占有而受到影响。”即我国民法典认可债权受让人承继债权转让人对债务人的全部债权权利，包括担保从权利。第七百条规定保证人享有债权人对债务人的权利，本意并非限制债权行使的对象或只享有移转而来的主权利，而是在该条预设的前提并不包括其他从权利，债权行使的对象只有主债务人。至于履行了保证责任的保证人，存在第五百四十七条、第五百一十九条第二款等情形时，可通过体系解释，即该保证人在享有债权人对债务人权利的同时，也取得与债权相关的从权利，自然包括保障主债权实现的其他保证债权和担保物权，都由保证人因清偿而承受。因此，保证人代偿后享有完全债权代位权。

三、保证人的追偿权与债权人的剩余债权的关系

（一）保证人的代位追偿权相对于主债权具有劣后性

民法典第五百一十九条第二款和第七百条均规定“但是不得损害债权人的

利益”，关于不得损害债权人的利益的理解，对第五百一十九条的解读通常为，清偿债务的连带债务人取得的债权人的权利应劣后于债权人的债权，即债权人的债权即使没有担保，也要优先保护。同理，民法典第七百条的但书条款表达了相同的含义。即便保证人的求偿权与债权人的剩余债权是平等的，都享有债权人的权利，但前者属于拟制享有债权人的权利，因此，在保护上，二者应存在区别。当保证人履行保证债务不足以相对消灭主债务时，比如保证合同中约定保证人仅担保主债权的本金，则保证人清偿保证债务后债权人仍对利息等从权利对主债务人享有债权。“不能损害债权人利益”的规定，即保证人享有的代位追偿权劣后于债权人的剩余债权。

（二）实践中的具体应用

1. 主债尚未清偿的情形下履行了保证责任的保证人能否通过诉讼的方式向债务人主张权利。在无特别约定的情形下，履行了保证责任的保证人享有债权人对债务人的权利，当保证人仅履行了部分保证责任或履行了全部保证责任但不足以消灭主债务时，由于保证人的代位追偿权相对于主债权具有劣后性，保证人可否先行起诉债务人主张权利，还是待主债清偿完毕后，才能向债务人主张权利。基于保证人行使追偿权的条件已经成就，且保证人无法及时准确知晓主债何时清偿完毕的现实情况，依据民法典第七百条之规定，保证人清偿后即享有追偿权且可通过诉讼的方式向债务人主张权利，但因主债尚未清偿完毕，追偿权的行使需受一定限制，此处不再赘述。

2. 保证人的代位追偿权相对于主债权的劣后性在裁判文书中如何表述。一是对保证人的代位追偿权的劣后性问题，应当在说理部分予以阐述，即为何平等的债权，在保护上又存在先后顺序。二是对保证人的代位追偿权的劣后性，应在判决中予以明确，即判决债务人向保证人偿还代偿款并附加履行限制，可通过加括号的方式明确劣后性，如案例的表述（主债权尚未清偿完毕之前，侯某不得向某房地产公司清偿前述款项，除非主债权人同意）。

四、其他担保方式可以参照执行

民法典第四百六十七条第一款规定：“本法或者其他法律没有明文规定的

合同，适用本编通则的规定，并可以参照适用本编或者其他法律最相类似合同的规定。”民法典仅对保证担保人履行保证责任后行使追偿权进行了规定，抵押、质押担保的基本原理与保证担保，在无明文规定时，可以参照民法典第四百六十七条规定进行裁判，在法条引用上，除了引用民法典关于抵押或质的条款外，还应当引用民法典第四百六十七条和第七百条之规定。

编写人：重庆市江北区人民法院 邓忠明

4

抵押权设定之日开发商的阶段性担保责任即告完成

——某银行诉张某、某置业公司金融借款合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省吉安市安福县人民法院(2024)赣0829民初869号民事判决书

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人

原告：某银行

被告：张某、某置业公司

【基本案情】

张某向某银行申请购房贷款，某银行与张某、某置业公司共同签订了《个人房产借款及抵押合同》，约定某银行向张某发放贷款，合同约定了借款期限、借款利率、保证人的保证责任等。合同另约定，由张某以其购买的某房屋提供抵押担保，某置业公司为此提供阶段性连带责任保证担保并约定了保证期限。另查明，某银行就该房屋办理了抵押预告登记，但张某尚未办理房地产权证及

正式的房地产抵押登记手续。

合同签订后，某银行如约发放贷款，张某自2022年1月21日开始逾期，未能按约定偿还上述贷款及利息。某银行遂主张张某还本付息，办妥其抵押房屋的登记手续并确认对该房屋享有优先受偿权。同时，某银行要求某置业公司承担连带责任。

【案件焦点】

开发商的阶段性担保责任是否完成。

【法院裁判要旨】

江西省安福县人民法院经审理认为：某银行与张某、某置业公司签订的《个人房产借款及抵押合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同的约定履行义务。某银行依约按张某委托发放贷款至某置业公司银行账户内，张某应按约及时还本付息。现张某未按合同约定偿还贷款本息，其行为已构成违约，应当承担违约责任。

关于某银行对被告张某的优先受偿权问题。张某以某房屋为上述贷款办理抵押预告登记。案涉抵押商品房办理了房屋产权人为某置业公司的房屋所有权首次登记，且抵押预告登记与所有权首次登记的财产标的完全一致。截至起诉之日某银行的债权尚未消灭，案涉商品房未办理抵押登记系由于张某个人原因，某银行不存在怠于抵押权登记的情形，本案的抵押预告登记仍处于有效状态。因此，某银行要求就张某的案涉房屋享有抵押权并优先受偿，合法有据，本院予以支持。

关于某置业公司的阶段性保证责任问题。阶段性保证是为防控银行在贷款发放之后、房屋抵押权设立之前面临的风险，由房地产开发商自愿在该期间内为借款人的还款义务所提供的连带保证。一旦房屋抵押设定成功，阶段性保证的任务就告完成，银行获得抵押担保之日即为开发商阶段性保证责任解除之时。本案中，某银行已对案涉房屋享有抵押权并优先受偿，原告的债权已得到保障，某置业公司的阶段性保证应予解除，故某银行主张被告某置业公司承担连带保

证责任，本院不予支持。江西省安福县人民法院判决如下：

一、张某在判决生效之日起十日内偿还某银行贷款本金390999.88元，利息1699.76元(利息已计算至2024年1月18日，之后的贷款利息、复利、罚息按合同约定支付至借款实际还清之日止)；

二、张某若未能履行本判决第一项确定的义务，某银行有权就张某提供的抵押物即某房屋从折价、拍卖或者变卖价款中优先受偿；

三、驳回某银行的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

商品房按揭贷款是购买期房的主要方式，为了降低房贷融资的风险，开发商会为该笔贷款提供阶段性保证。审判实践中，开发商已经办理了“大产证”即建筑物所有权首次登记，银行和购房者办理了抵押预告登记，但有大量购房者，在多次催告后仍不去办理正式抵押登记或不动产权证书。如何在审判中准确把握开发商的阶段性担保责任是否完成，是本案中值得研究探讨的重点问题。

抵押的预告登记在不动产预售买卖中十分常见，通常是抵押人将房屋抵押给银行，以担保银行的债权，但因为预售房屋尚无法办理抵押登记，所以只能办理抵押的预告登记。所谓抵押预告登记，是在抵押登记暂时无法办理时，当事人为确保将来取得抵押权而办理的一种特殊登记，其目的在于当能够办理抵押登记时，预告登记权利人能够获得较其他担保物权人或债权人更加优先的顺位。2021年1月1日起施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条对抵押预告登记如何实现抵押权进行了规定。主要条件有三个，首先是需要办理完毕房屋所有权的首次登记(即“大产证”)，其次是抵押预告登记与所有权首次登记的财产标的一致，最后是抵押预告登记未失效。在满足上述条件时，即可认为抵押权自预告登记之日起设立。自《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》实施以来，目前法院基本都会按照该解释第五十二条的规定来认定抵押预告登记的优先效力。

在向银行贷款购买房屋的案件中，银行为保障自身权益的实现，通常会要求开发商提供阶段性担保，即银行发放贷款之日起至实际取得房屋抵押权之日止，开发商为房屋贷款提供连带责任保证。由此可知，开发商连带责任保证的解除条件为房屋抵押权的实际取得。

购房人因逾期偿还借款而断供，在房屋没有办理完毕抵押权登记的情况下，银行对房屋是否享有抵押权及开发商是否承担阶段性连带担保责任，应区分不同情况分别进行判断分析。情形一：因购房人原因导致未能办理或不配合办理抵押登记的，银行取得抵押权，开发商连带保证责任免除。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条，如开发商已就房屋办理了产权登记，具备了办理抵押权登记的条件，对于未能完成抵押登记不存在过错，其阶段性担保责任应当予以免除。情形二：因开发商原因导致未能办理抵押登记，开发商的连带责任不能免除。阶段性保证设立的初衷在于降低正式产权登记未完备导致的债权清偿风险，促使开发商及时完成项目开发建设，积极协助办理产权登记手续。如房屋未能正式办理产权登记的原因在于开发商不具备办理抵押登记的条件，开发商的保证责任不能免除。

阶段性担保责任作为房地产行业潜在债务的重要组成部分，阶段性担保与房屋抵押担保互为承继而非并存关系，所以通过明确开发商阶段性担保责任的解除条件，使其免于负担不必要的、过重的连带赔偿责任，如果仅因未取得抵押登记权证而让银行享有开发商的连带责任保证及房屋抵押的双重担保，无疑与缔约目的相悖，也有违诚实信用原则，缺乏经济上的合理性和正当性。在能够保障银行贷款风险防控的同时，实现开发商债务负担的分配正义，一定程度上有利于实现金融和房地产市场长远稳定发展。

编写人：江西省吉安市安福县人民法院 刘恋

分期手续费实为利息，预收部分应当抵扣借款本金

——某银行顺德某支行诉甘某金融借款合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省佛山市顺德区人民法院(2023)粤0606民初23620号民事判决书

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人

原告：某银行顺德某支行

被告：甘某

【基本案情】

2019年6月18日，某银行顺德某支行与甘某签订《信用卡分期业务借款合同》，约定借款金额300000元，分期期数60期，分期手续费39000元，贷款以信用卡透支形式发放，分期手续费采用一次性收取方式。合同签订后，某银行顺德某支行在发放借款本金至甘某信用卡后当日，将分期手续费一次性扣收。甘某在合同期内履行了部分还款义务后出现多次逾期还款行为，某银行顺德某支行遂向法院提起诉讼。

【案件焦点】

分期手续费性质及收取合理性的认定。

【法院裁判要旨】

广东省佛山市顺德区人民法院经审理认为：甘某在案涉信用卡项下申请专

项分期后未按期还款，已构成违约，某银行顺德某支行有权依据分期业务细则约定提前收回全部的分期本金。另根据双方合同约定，分期手续费39000元按照13%收取，该分期手续费实际系利息的收取，而某银行顺德某支行在借款当日即一次性收取，并非按照分期的要求逐期收取。某银行顺德某支行在放款当日即收取该费用，应当视为提前收取了整个借款期间的利息。但是甘某案涉的借款由于违约提前到期，某银行顺德某支行同时主张了到期日之后的逾期利息等费用，故其有权收取提前到期日止的分期手续费，未实际到期的分期手续费应当视为本金进行抵扣。

广东省佛山市顺德区人民法院判决如下：

一、甘某应于判决发生法律效力之日起十日内向某银行顺德某支行清偿信用卡透支本金147999.76元、利息（暂计至2022年6月10日利息为330.83元，此后的利息以透支款本金147999.76元为基数，按日利率万分之五计至清偿之日止）、违约金477.43元；

二、驳回某银行顺德某支行的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

一、信用卡分期消费贷的性质

《银行卡业务管理办法》第六条第二款规定：“贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后还款的信用卡。”该办法第二十条规定免息还款期最长为60天。根据上述规定可知，信用卡业务的基本交易方式为金融消费者使用信用卡在规定的限额内透支消费。同时，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》中规定“刑法规定的‘信用卡’，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡”，即信用卡的交易方式除了上述的普通消费支付还包括信用贷款

的交易方式。①本案中，双方签订的协议名称为借款合同，条款内容主要系贷款金额、分期期数，还款方式。该约定的内容与传统借款合同的内容无异，故本案系以信用卡方式发放分期贷款的金融借款合同纠纷。

二、分期手续费性质的认定

在以信用卡方式发放贷款的交易中，一方面书面协议以借款合同之名约定主要权利义务，另一方面以信用卡领用合约条款对违约的透支利息、违约金等进行约定，故其兼具信用卡消费支付及信用贷款的双重属性。因协议的基本属性仍为借款合同关系，银行作为放贷机构发放贷款需要收取相应的借款利息。但是在信用卡分期消费贷中持卡人在约定还款期限内透支消费不产生利息，而是约定分期手续费，手续费金额固定、期限固定，并约定按照年利率的方式计算，该情形实与借款利息的构成相似，故分期业务的手续费实质应为借款期间的利息。《银保监会、人民银行关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》关于“全面加强信用卡分期业务规范管理”的第二十一条规定“……向客户展示分期业务收取的资金使用成本时，应当统一采用利息形式，并明确相应的计息规则，不得采用手续费等形式”，亦明确认定信用卡分期手续费的性质应为利息。

三、本案的手续费的收取合理性认定

如前所述，所谓分期手续费实质为借款合同的利息，则该费用的收取应当适用法律法规关于利息收取的规定。案涉合同签订于2019年，按照原《中华人民共和国合同法》第二百条的规定，借款的利息不得预先在本金中扣除②。而某银行顺德某支行在发放贷款当日一次性收取借期内全部手续费，属于预收利息，变相地减少了向借款人发放的贷款本金数额，致使借款人并未能享有合同约定的全额借款本金的使用权利。该行为违反了法律的规定，其一次性收取手

①《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十一条规定：“发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条‘恶意透支’的规定。构成其他犯罪的，以其他犯罪论处。”该解释亦明确了信用卡透支形式的信用贷款方式。

②该条款被《中华人民共和国民法典》第六百七十条所承继。

续费不具合理性，故应当认定未到期手续费为预扣利息，在借款本金中直接予以扣除。

同时，在信用卡分期业务的审查中发现，借款人往往会被“0利率”或者“低手续费率”的宣传诱导而办理分期消费贷，然而分期手续费本身即为利息性质，所谓的“0利率”并非借款人朴素认知中理解的没有利息的意思表示，这种信息不对称的情况可能导致借款人的知情权受损。而若是借款人出现逾期情形，除需支付手续费外，还将承担支付日万分之五的透支利息及相应违约金的违约责任，实质的利费标准可能远超其合理预期。《银保监会、人民银行关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》已经明确将信用卡分期业务中的分期手续费的利息性质予以认定，并要求金融机构应当尽快完成分期业务中手续费转利息的调整，合法合理确定金融消费产品的费用收取标准，保障金融消费者的合法权益，亦即金融机构在此后的信用卡分期业务中，不得再以分期手续费的方式收取利息，必须明确分期利息的收取标准。在此情况下，对于借款逾期后分期利息及透支利息同时产生时的收取合理性的认定则需要区分不同阶段进行审查处理：

1. 2016年4月15日①至2020年12月31日；

2. 2021年1月1日②之后。

依照上述情况可知，对于2021年1月1日前的信用卡分期消费持续至手续费转化为分期利息的存量业务，此时由于双方约定的利息上限为日万分之五，除双方另有约定外，对于转化后的分期利息因超出利息上限不应支持。对于2021年1月1日取消上限之后产生的信用卡分期利息则应当以双方协议约定的

①中国人民银行于2016年4月15日发布《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》第一条规定：“对信用卡透支利率实行上限和下限管理，透支利率上限为日利率万分之五……”

②中国人民银行于2020年12月31日发布《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》规定：“……为深入推进利率市场化改革，中国人民银行决定，自2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理……”

标准进行审查为宜。但是仍应以年利率24%的标准作为上限，对收取的透支利息、分期利息及违约金等费用的合理性进行审查认定^①。

编写人：广东省佛山市顺德区人民法院 王成春

6

借款人以银行未对勾选的借款利率条款、
罚息和复利条款进行提示说明为由，主张以上条款
不成为合同内容的，依法不予支持

——黄某某诉某银行金融借款合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

成渝金融法院(2023)渝87民终6271号民事判决书

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):黄某某

被告(被上诉人):某银行

第三人：某实业公司、陈某某、张某某、某贸易公司

^①《最高人民法院印发〈关于进一步加强金融审判工作的若干意见〉的通知》规定：“严格依法规制高利贷，有效降低实体经济的融资成本。金融借款合同的借款人以贷款人同时主张的利息、复利、罚息、违约金和其他费用过高，显著背离实际损失为由，请求对总计超过年利率24%的部分予以调减的，应予支持，以有效降低实体经济的融资成本。规范和引导民间融资秩序，依法否定民间借贷纠纷案件中预扣本金或者利息、变相高息等规避民间借贷利率司法保护上限的合同条款效力。”

【基本案情】

2015年6月10日,某银行(贷款人)与黄某某(借款人)签订《个人经营贷款借款合同》,约定借款金额1500万元,借款期限为2015年6月19日至2025年6月18日。该合同第四条共载明四种借款利率,勾选确定的借款利率采用如下执行标准:借款利率按法定基准利率(上浮☒/下浮/相等)50%执行,即借款年利率为8.475%,借款期限一年以内(含一年)的,按合同利率执行,借款期限一年以上的,遇法定基准利率调整,于次年1月1日按本合同约定的浮动标准执行新的利率,贷款人不再另行通知借款人。合同第十一条载明:如借款人未按约定期限还款且未就展期事宜与贷款人达成协议,贷款人有权就贷款逾期部分从逾期之日起按照贷款逾期罚息利率计收罚息,直至借款人完全清偿本息为止。逾期是指:(1)到期一次性还本付息的,到期未偿还的;(2)分期按计划还款的,一次到期未偿还的。贷款逾期罚息利率为本合同约定借款利率的150%。如借款人未按期足额付息,贷款人有权就到期未付利息部分按照与贷款本金相同的罚息利率计收复利。计收罚息和复利,遇本合同约定的借款利率调整,自调整之日起分段计算罚息和复利。借款人偿还违约本息的顺序为先偿还最先违约期数的本息,再按顺序依次偿还。合同第二十七条载明特别提示,借款人已经与贷款人就本合同中的所有条款进行了充分的协商;贷款人已提请借款人特别注意有关双方权利义务的全部条款,借款人对其有全面、准确的理解;贷款人已经应借款人的要求对上述条款做出相应的说明;签约各方对本合同条款的理解完全一致。黄某某在借款人处签字捺印。合同另就借款用途、还款方式等事项进行约定。签订合同后,某银行按约发放了贷款。黄某某如期偿还借款本息至2020年5月20日,之后再未履行还款义务。其后,黄某某认为借款合同中的借款利率条款、罚息和复利条款系格式条款,以某银行未履行提示说明义务为由向法院起诉,主张借款合同的第四条、第十一条不成为合同内容。

【案件焦点】

《个人经营贷款借款合同》的第四条、第十一条是否可以不成为合同的内容。

【法院裁判要旨】

重庆自由贸易试验区人民法院经审理认为：依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第九条的规定，认定《个人经营贷款借款合同》第四条、第十一条是否可以不成为合同内容应当适用《中华人民共和国民法典》第四百九十六条的规定。

《中华人民共和国民法典》第四百九十六条规定：“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。”

本案中，案涉借款合同第四条的借款利率共有4项执行标准，各项标准均有留白供合同当事人手写勾选，某银行、黄某某执行的借款利率标准为按法定基准利率（上浮☑/下浮/相等）50%。该条款显然并非未经当事人协商，黄某某主张第四条为格式条款的理由不能成立。《中华人民共和国民法典》第四百九十六条规定应当提示和说明的条款是“免除或者减轻提供格式条款一方责任等与对方有重大利害关系的条款”，而案涉借款合同第十一条有关罚息利率、复利等的约定属于违约条款，并未违反中国人民银行关于金融机构利率的规定，仅在合同当事人存在违反借款合同约定的行为时才会产生罚息、复利，故该约定不属于免除或者减轻某银行责任的条款，也并未加重借款人责任、排除借款人权利。故黄某某主张案涉借款合同第十一条不成为合同内容，缺乏依据。

重庆自由贸易试验区人民法院判决如下：

驳回黄某某的诉讼请求。

黄某某不服一审判决，提起上诉。成渝金融法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

格式条款一般由居于垄断地位的一方预先拟定，格式合同条款的对方当事人处于从属地位。格式条款具有便捷、易行、高效的优点，缺点是双方当事人的经济地位不平等致使无协商余地。本案即涉及金融借款合同中的借款利率条款、罚息和复利条款是否属于格式条款以及可否不成为合同内容的问题。该案件的裁判规则可以为该类条款是否不成为合同内容提供认定思路。

依照民法典第四百九十六条的规定，当事人主张合同条款不成为合同内容的，应当考虑以下情况：

一、合同条款是否系格式条款

民法典第四百九十六条第一款规定：“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。”据此，是否构成格式条款应当考虑两项条件：（1）合同条款系当事人为了重复使用而预先拟定；（2）订立合同时未与对方协商。在法律条文的语义表述上，两个条件之间的连接词为“并”。因此，合同条款应当同时满足前述两个条件，才属于格式条款。

二、格式条款的内容是否公平，是否履行提示、说明义务

民法典第四百九十六条第二款规定：“采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明……”据此，在合同条款构成格式条款的前提下，格式条款提供方应当遵循公平原则确定双方的权利义务。若格式条款免除或者减轻格式条款提供方的责任或者与对方有重大利害关系，格式条款提供方应当采取合理的方式提示对方注意，并按照对方要求予以说明。

三、对方是否注意或者理解与其有重大利害关系的条款

民法典第四百九十六条第二款规定：“……提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。”据此，合同相对方主张格式条款不成为合同内容的，应当同时满足三项条件：(1)格式条款提供方未履行提示或者说明义务；(2)对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款；(3)“未履行提示或者说明义务”与“对方没有注意或者理解”存在因果关系。

民法典第四百九十六条是立法机关在市场交易的公平性和便捷性之间进行价值考量而缔造的法律条款。通过对该条的规定进行文义解释、体系解释，可以发现认定格式条款不成为合同内容的多项前提条件在逻辑上存在并列、递进、因果关系。司法机关应当严格依照该条的规定审查前提条件是否成就，各项前提条件之间是否存在前述关系，判断格式条款不成为合同内容的主张能否成立，在鼓励交易原则和公平原则之间进行价值评判。

编写人：重庆两江新区人民法院(重庆自由贸易

试验区人民法院) 李亚飞 何佳杰

金融机构已取得按揭房屋抵押权的情况下 开发商的阶段性担保责任应当免除

—— 某银行新会支行诉某房地产公司等金融借款合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省江门市中级人民法院(2023)粤07民终237号民事判决书

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某银行新会支行

被告(被上诉人):某房地产公司

被告:张某某、李某某

【基本案情】

2018年11月6日,某银行新会支行与张某某、李某某夫妇签订《个人购房借款/担保合同》,约定某银行新会支行向被告张某某、李某某发放个人一手住房购置消费贷款710000元,用于购买某房屋。张某某、李某某同意以其在本合同项下的全部债务提供最高额抵押担保。双方签订上述合同后,某银行新会支行依约发放了710000元贷款,双方亦于2018年12月19日就涉案房屋办理预售商品房买卖预告登记、抵押预告登记。自2021年4月起,张某某、李某某出现逾期还款情况,截至2021年11月10日,连续7期并累计8期未按约定足额还本付息。

某房地产公司系案涉房屋的开发商。2018年7月10日,某房地产公司与某银行新会支行签订《按揭贷款业务合作协议》,约定在借款人办妥正式抵押登记手续(不含预告抵押登记),并将《房屋他项权证》(或《不动产登记证明》)交某银行新会支行收押之前,某房地产公司同意为借款人(购房人)提供阶段性连带责任保证担保,担保范围包括贷款本金、利息、复利、罚息和为实现债权而产生的费用。

另查明,2019年9月26日,某房地产公司取得了涉案房屋的《商品房权属登记证明书》,但直至本案法庭辩论结束之日仍未过户至张某某、李某某名下。

【案件焦点】

1. 某银行新会支行对案涉房屋是否享有优先受偿权; 2. 某房地产公司的阶段性担保责任是否应免除。

【法院裁判要旨】

广东省江门市新会区人民法院经审理认为：第一，关于张某某、李某某应偿本息的问题。张某某、李某某借款后未按约定还款付息，其行为已构成违约，理应承担违约责任。某银行新会支行宣布所有已贷出的贷款立即到期，并要求被告张某某提前偿还尚欠本金、相应利息（含罚息）及复利，符合双方的约定，法院予以支持。经核，截至2021年11月10日，张某某、李某某尚欠贷款本金688894.6元以及利息（含罚息复利）23464.2元。第二，关于某银行新会支行是否对案涉房屋享有优先受偿权的问题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条第一款规定：“当事人办理抵押预告登记后，预告登记权利人请求就抵押财产优先受偿，经审查存在尚未办理建筑物所有权首次登记、预告登记的财产与办理建筑物所有权首次登记时的财产不一致、抵押预告登记已经失效等情形，导致不具备办理抵押登记条件的，人民法院不予支持；经审查已经办理建筑物所有权首次登记，且不存在预告登记失效等情形的，人民法院应予支持，并应当认定抵押权自预告登记之日起设立。”涉案房产已经办理建筑物所有权首次登记，且不存在预告登记失效等情形，据此，在该房产已办理抵押预告登记的情况下，应当认定抵押权自预告登记之日即2018年12月19日起设立。某银行新会支行主张对案涉房产拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权的理据充分，法院予以支持。第三，关于某房地产公司的阶段性保证责任问题。本案中，某银行新会支行与某房地产公司在涉案《按揭贷款业务合作协议》约定，在借款人办妥正式抵押登记手续，并将《房屋他项权证》交某银行新会支行收押之前，某房地产公司同意为借款人（购房人）提供阶段性连带责任保证担保。双方约定某房地产公司承担阶段性连带保证责任的目的在于排除因抵押权未能设立而带来的借贷风险，在法院认定某银行新会支行对涉案房产抵押权已于2018年12月19日设立的情况，某银行新会支行与某房地产公司订立上述合同的目的已实现，相应的某房地产公司对涉案债务的保证期间应提前届满，故某银行新会支行诉请被告某房地产公司承担连带责任的理据不足，法院不予支持。

广东省江门市新会区人民法院判决如下：张某某、李某某应向某银行新会支行偿还本金688894.6元以及相应利息，某银行新会支行对张某某、李某某名下房屋折价抵债或拍卖、变卖所得款项享有优先受偿权，驳回某银行新会支行的其他诉讼请求。

某银行新会支行不服一审判决，提出上诉。广东省江门市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

所谓阶段性担保，通常是指借款人以其所购房屋办理抵押贷款时，在办理《房屋所有权证》及《国有土地使用证》之前，由开发商等为贷款担保，担保的期限自银行放款之日起至抵押登记办理完毕，银行执管《房地产其他权利证明》之日止。设立阶段性担保的目的在于保护金融机构的抵押权以及保障购房者的合法权益。在民法典实施之前，预告抵押登记仅具有对抗第三人的效力，无法直接产生抵押权效力，抵押权登记条件成就时，金融机构享有办理正式抵押登记的请求权。民法典施行后，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条第一款明确规定，当事人办理抵押预告登记后，预告登记权利人请求就抵押财产优先受偿……经审查已经办理建筑物所有权首次登记，且不存在预告登记失效等情形的，人民法院应予支持，并应当认定抵押权自预告登记之日起设立。可见，民法典框架下，当满足法律规定的条件时，抵押权可自预告抵押登记之日起设立。本案中，开发商已为案涉商品房办理建筑物所有权首次登记，在购房人（借款人）怠于办理预告抵押登记的情况下，预告抵押登记仍处于有效状态，案涉房屋抵押权自预告登记之日起成立。在此情况下，房地产开发商的阶段性担保责任应予以免除，具体理由如下：

1. 从阶段性担保之合同目的来看，设立阶段性担保的主要目的在于约束房地产开发商如约竣工验收交付预售房屋，促使预售商品房及时满足办理正式抵押权的条件，进而保障金融机构的债权。本案中，在案涉预售商品房已办理

建筑物所有权首次登记的情况下，抵押权在预告抵押登记之时即已设立，金融机构的债权已因此获得受偿保障，故阶段性担保合同之目的已实现，相应地，房地产开发商对涉案债务的保证担保期间应提前届满。

2. 从阶段性担保的特点来看，房地产开发商的担保具有明显的阶段性，该阶段性担保与抵押权并非并存关系，而是先后承接关系。在阶段性担保中，金融机构作为预告抵押登记的权利人，其有义务协助和督促购房人（借款人）及时办理正式抵押登记，如果在购房人怠于履行抵押登记义务的情况下仍认定房地产开发商承担保证责任，相当于无限期延长房地产开发商的担保期间，如此无疑显失公平。

3. 从阶段性担保的民事法律行为属性来看，阶段性担保属于附解除条件的民事法律行为，在金融机构取得正式抵押权的情况下，房地产开发商的阶段性担保责任即完成。在可以办理正式抵押权登记的情况下，金融机构或购房者（借款人）怠于履行办理的，客观上阻却了免除开发商保证责任条件的成就，应视为解除条件成就，开发商的阶段性保证责任应予以免除。

编写人：广东省江门市新会区人民法院 冯万常 张碧媛

金融机构善意取得抵押权中“善意”的认定规则

—— 某银行诉杨某金融借款合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院（2023）京74民终798号民事判决书

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某银行

被告(被上诉人):杨某

【基本案情】

2015年5月8日,某银行与杨某签订了《个人住房(商业用房)借款合同》(以下简称《借款合同》),杨某向某银行借款购买涉案房屋,借款金额为189万元,借款期限为360个月,贷款利率为年利率,执行浮动利率,即在基准利率水平上下调10%;借款逾期的,罚息利率为在《借款合同》执行贷款利率的水平上上浮50%。还款方法为等额本息还款,担保方式为抵押。2015年5月27日,杨某将上述房屋办理了抵押登记,抵押权人为某银行。2021年11月1日,北京市朝阳区人民法院作出(2020)京0105刑初674号刑事判决书,杨某等人以办理房屋抵押贷款为名,诱使被害人李某某签订短期借款合同,向其隐瞒办理售房委托公证的法律后果,对售房委托书进行公证之后,在被害人李某某不知情的情况下,将其房屋私自过户到杨某的个人名下或者再转卖他人,被害人李某某并不具有出售房屋的真实意愿,判决查封杨某名下涉案房屋,发还给被害人李某某。该判决现已生效。上述合同签订后,原告于2015年6月1日依照《借款合同》的约定发放了借款189万元,履行了合同约定的义务。但杨某未按照约定履行还款付息义务,已构成违约。根据《借款合同》约定,原告有权宣布贷款立即到期,要求借款人立即清偿借款本息及相关费用。故原告诉至法院,请求判令:1.判令杨某清偿原告截至2022年5月31日的借款本金1666461.7元、利息41109.03元、罚息1054.34元,合计1708625.07元,并支付自2022年6月1日起至全部清偿本息之日止的相应罚息(按照《个人住房(商业住房)借款合同》约定的标准计算);2.判令某银行对杨某提供的抵押物折价或以拍卖变卖后的价款享有优先受偿权;3.本案诉讼费由被告承担。

【案件焦点】

某银行是否善意取得涉案房屋的抵押权。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：某银行与杨某所签的《借款合同》是双方当事人真实意思表示，内容不违反国家法律、行政法规的强制性规定，合同有效。各方当事人均应当按照约定履行各自的合同义务。某银行依约发放了贷款，杨某应按合同约定的期限履行还款义务。杨某向某银行贷款购房后，至今已多次逾期未按合同约定向某银行偿还贷款本金及利息，致使某银行与杨某所签借款合同目的不能实现，已构成违约。某银行要求杨某偿还所有剩余借款本金、利息、罚息的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。

关于某银行是否善意取得涉案房屋的抵押权。李某某作为被害人，将涉案房屋过户到杨某名下并非其真实意愿，现北京市朝阳区人民法院已判决将涉案房屋发还给李某某，故涉案房屋的登记状态与实际状态并不相符。《中华人民共和国商业银行法》第三十六条第一款规定，商业银行应当对保证人的偿还能力，抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查。某银行作为专门从事借贷业务的商事主体，在出借款项、办理抵押之前没有至案涉房屋内进行查勘，对涉案房屋的权属、现状以及实现抵押权的可能性未进行严格审查，存在重大过失，不符合法律规定的善意取得的要件，无法被认定为善意第三人，不能依法取得案涉房屋的抵押权。故对于某银行要求对涉案房屋行使抵押权的诉讼请求，本院不予支持。

北京市丰台区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国物权法》第一百零六条之规定，判决如下：

一、杨某于本判决生效之日起十日内偿还某银行借款本金1666461.7元，截至2022年5月31日的利息41109.03元、罚息1054.34元，并支付自2022年6月1日起至全部本息清偿之日止的相应罚息（按照《个人住房（商业用房）借款合同》约定的标准计算）；

二、驳回某银行的其他诉讼请求。

某银行不服一审判决，提起上诉。北京金融法院经审理认为：某银行在二审期间提交的《存量房屋买卖合同》，较正常的房屋交易合同存在诸多可疑之处，某银行作为专业金融机构在贷款审查、风控环节未尽到充分注意义务，因此其未充分履行《中华人民共和国商业银行法》中规定的商业银行贷款的严格审查义务。据此，某银行不符合《中华人民共和国物权法》第一百零六条规定的善意取得的条件，存在重大过失，不能依法取得涉案房屋的抵押权，因而不享有将涉案房屋折价或者拍卖、变卖后的价款的优先受偿权。因此，某银行提出的要求依法改判其对杨某提供的抵押物折价或者拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权的上诉请求不能成立，本院不予支持。依照《个人贷款管理暂行办法》第十六条第一款，贷款人在不损害借款人合法权益和风险可控的前提下，可将贷款调查中的部分特定事项审慎委托第三方代为办理，但必须明确第三方的资质条件。某银行委托北京某房地产评估有限责任公司对涉案房产进行现场评估，符合《个人贷款管理暂行办法》的规定。一审法院据此认定某银行存在重大过失，不符合法律规定的善意取得的要件，无法被认定为善意第三人，不能依法取得案涉房屋的抵押权，存在瑕疵。但是，该瑕疵并不影响某银行不构成善意取得，不能依法取得涉案房屋抵押权的结果。

北京金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在金融领域中，抵押贷款是最为常见的融资方式，不动产房屋往往作为最常见的抵押物在融资中广泛使用。我国民法典第三百一十一条规定了善意取得制度，该制度的适用前提和构成要件主要包括处分行为为无权处分、已支付合理对价、完成公示和受让人主观善意，相对于前三个构成要件，司法实践中，对于金融机构善意取得抵押权时主观上是否“善意”的认定标准存在争议。本文尝试从本案的争议焦点出发探究金融机构善意取得不动产抵押权时“善意”认定的边界。

一、金融机构“善意”的认定

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释(一)》第十四条明确了受让人善意的认定标准为受让人不知且非因重大过失而不知转让人无权处分，以及对于善意的认定采取推定方式，即先推定受让人为善意，再由真实权利人就受让人非善意进行举证证明，若真实权利人无法证明，则认定受让人为善意，同时第十六条和第十七条规定了如何认定重大过失。笔者认为，对于一般人而言，只要受让人在受让时通过房屋登记情况和占有状况的外观进行判断后未能知道转让人无处分权，其即可构成善意而不必过分进行苛责。但金融机构作为专业机构则不同，实务中一般赋予金融机构在尽职调查过程中更高的注意义务，而法律规定的不明确导致法院在金融机构抵押权取得过程中的善意认定存在较大争议和分歧。根据上述司法解释规定的精神，要求抵押人在办理抵押登记过程中对抵押物实际权属不得有故意或者重大过失情节，即不存在知道或应当知道抵押物已存在真实权利人，否则不构成善意。因此，在认定善意的过程中，笔者认为应结合主客观标准综合认定：

(一)客观标准：金融机构不明知抵押人无处分权

该标准为消极事实，抵押权人即金融机构无须也无法举证证明。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释(一)》第十五条规定的五种情形即属于受让人明知转让人无处分权的情形，真实权利人可通过举证证明以下两类事实来证明抵押权人知道抵押人无处分权，反推抵押权人并非善意。

1. 不动产登记簿上载有对不动产无权处分的限制事项

不动产登记簿具有公示及权利推定效力，那么其上记载的内容就应推定为抵押权人知晓的内容。

2. 抵押权人知道抵押人无处分权

真实权利人既可以举证证明抵押权人对于登记簿上记载的权利主体错误是知晓的，比如抵押权人事先知晓登记权利人和真实权利人之间的关系，或是知晓存在登记错误，也可以举证证明抵押权人事先知道他人已经依法取得不动产

物权，如因法院、仲裁机构的法律文书等方式取得物权的情形。

(二) 主观标准：金融机构对不知道抵押人无处分权无重大过失

1. “无重大过失”的认定

该项认定要结合交易主体、背景和过程等事实作分析。受让人不应当知道转让人非为权利人且无重大过失，此所谓应当知道转让人无处分权，该知之与否，非绝对之真事实，乃为最可能之盖然性，受让人有悖于诚信原则时不得推诿不知，受让人依交易经验可得转让人无让与权之结论时应认定恶意。^①笔者认为，一般理性人在通常情况下尽到注意义务即可得知抵押人无处分权，而抵押权人却因消极注意而不知晓，即可认定抵押人存在重大过失。银行作为从事金融贷款业务并以房屋抵押为常规担保手段的金融机构，对于接收房屋作为抵押物可能存在的风险具有不同于一般社会公众的预见性和经验，具备高于一般社会公众的甄别能力，因此应被赋予更高的注意义务。

2. 金融机构应负有更高的“注意义务”

银行作为专业的金融机构，负有“贷款三查”（贷前调查、贷时审查、贷后检查）义务，且应遵循《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《贷款通则》《个人贷款管理办法》《商业银行房地产贷款风险管理指引》等的规定，银行发放抵押贷款，须经贷款调查、抵押物评估、贷款审批、合同签订、贷款发放、贷后检查等流程，因此银行对于抵押物的权属情况负有更高的注意义务。实务中，银行常见的可能存在重大过失的情形为：向关系人发放贷款；未严格审查借款人的负债情况；未审查转让人取得房产价格的公允性；未审查房产交易完成后短期内申请贷款的合理性；未实地调查抵押物的使用情况；经营用途贷款违规流入房地产领域；等等。

二、本案金融机构是否构成“善意第三人”的判断

从客观标准来说，行为人杨某在没有购买涉案房屋真实意愿的情况下，应朋友的要求配合办理房屋买卖、购房贷款等手续以套取银行贷款，虽然涉案房屋权属登记系在杨某名下，同时涉案房屋真实权利人客观上并无举证证明某银

^①史尚宽：《物权法论》，中国政法大学出版社2000年版，第564页。

行知道杨某无处分权的能力，但某银行作为专业的金融机构，在开展不动产抵押贷款业务的过程中，审查抵押人对抵押物是否享有合法、完整的处分权，既是其防范风险的必备措施，也是其应尽的审查义务。因此，按照商业银行法第三十六条规定，某银行仍应负有对涉案房屋的权属、价值以及实现抵押权的可能性进行尽职审查的义务。

从主观标准来说，某银行虽然在一、二审过程中抗辩称对涉案房产登记在杨某名下之前发生的情况不知情且无从发现，基于不动产公示原则相信杨某系有权处分人，对涉案房屋办理了抵押登记，我们能够理解，某银行为保证交易效率，对办理抵押登记手续的相关证明文件进行了形式审查，在房屋实地查勘方面也委托相关评估公司进行了实地评估，核查了涉案房产现状。但某银行在二审过程中提交的《存量房屋买卖合同》属于自行成交版本，其中关于房屋交易的重要条款约定过于简单，某银行也并未提交其他有效证据证明其在涉案贷款审查和风控环节尽到了充分的注意义务，因此应认定存在重大过失。值得注意的是，本案一、二审关于金融机构对涉案房屋是否进行实地查勘进而认定其是否存在重大过失有不同见解。笔者认为，在房屋过户至杨某名下后，被害人李某某一直在涉案房屋居住的事实已被法院认定，那么无论某银行委托的评估机构是否真实全面地向其反映涉案房屋的实际状态，某银行都应对此承担更高的审慎注意义务，具有勘验核实抵押物权属状况的便利和优势地位，理应尽到比一般人更高的注意义务，否则难言善意，一审法院据此直接认定某银行存在重大过失，笔者认为并无不妥，当然二审法院根据某银行提交的合同版本进一步细致审查出其在交易过程中的重大过失行为，不影响某银行不构成善意取得，不能依法取得涉案房屋抵押权的后果。笔者认为，未来金融机构需采取更加审慎严谨的尽职调查措施，确保抵押权取得完整、有效。

三、金融机构“善意”判断标准的完善

善意作为一种主观要件通常较难判断，因此司法实践中导致留存较大的自由裁量权。根据目前裁判文书中关于金融机构善意取得不动产抵押权时主观“善意”的认定主要存在形式审查义务和实质审查义务两种观点，判决结果也

截然不同。该两种观点的不同之处在于金融机构在审查抵押登记外观时，是应满足于一般注意义务即可，还是应被赋予更高的审慎注意义务，两种观点的分歧在于所保护的法益不同，第一种观点形式审查义务侧重于商事外观注意，保障市场交易秩序稳定和交易安全；第二种观点在所述法益的基础上，更侧重保护真实权利人的合法权益。本案中，一、二审法院均采纳了第二种观点。

目前世界各国对善意的判断标准各不相同，主要分三种：第一种为美国标准，善意不仅要求不知情，还应包括对商业上合理的公平交易标准的遵守；第二种为德国标准，不仅要求受让人处于不知情状态，还要求其在交易过程中没有出现重大过失；第三种为日本标准，虽然未提及受让人是否应当知情，但是要求其必须无过失才成立善意。^①笔者认为，对善意边界的划分应当结合美、德标准，提高对善意标准的认定，充分有效保障真实权利人的合法权利。未来，我国在立法上仍需对善意取得制度的适用范围、判断标准继续完善，以适应时代进步和变迁。

编写人：北京市丰台区人民法院 付晨晨 曹蕾

金融借款中配偶方“共债共签”意思表示的认定

——甲银行股份有限公司诉炊某甲等金融借款合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

河南省宜阳县人民法院(2023)豫0327民初4331号民事判决书

^①李桡、吕红蕾：《善意取得制度研究——以〈民法典〉为契机的思考》，载《法制博览》2022年第30期。

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人

原告：甲银行股份有限公司

被告：炊某甲、茹某某、炊某乙、刘某某、魏某某

【基本案情】

2020年8月1日，炊某甲与甲银行股份有限公司签订《最高额个人借款合同》约定：炊某甲向甲银行股份有限公司借款1800000元，借款期限24个月，至2022年8月1日；借款期间月利率9.5‰，按月结息，不定期还本；逾期利率在原利息基础上加收50%，茹某某在借款合同上签字确认其愿意与借款人共同承担还款责任。同日，炊某乙、刘某某、魏某某与甲银行股份有限公司签订《最高额保证合同》约定：自愿对炊某甲的上述债务承担连带保证责任，保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金以及为实现债权而产生的全部费用和损失等全部债权；保证期限为主债务履行期届满之日起三年。合同签订后，甲银行股份有限公司按照合同约定将借款本金1800000元支付至炊某甲指定账户。炊某甲曾偿还部分利息，但在借款期间未按照合同约定的时间足额支付利息，借款期满后也未清偿借款本息，经多次催要未果，甲银行股份有限公司提起本案诉讼。截至2022年9月26日，炊某甲尚欠甲银行股份有限公司借款本金1800000元，利息439708.67元。

【案件焦点】

炊某甲以个人名义向银行借款，茹某某作为配偶在借款合同的借款人配偶签名栏签字，明确表达愿意承担共同还款责任，是否构成共同借款的意思表示。

【法院裁判要旨】

河南省宜阳县人民法院经审理认为：原告甲银行股份有限公司与被告炊某甲、茹某某签订的《最高额个人借款合同》，与被告炊某乙、刘某某、魏某某签订的《最高额保证合同》均系合同各方当事人的真实意思表示，合法有效，

合同各方当事人均应按照合同约定全面履行合同义务。茹某某虽然未在借款合同中作为借款人签字，但其在借款合同签字栏中明确表达愿意承担共同还款责任并签字，应当认定其身份为共同借款人。被告炊某乙、刘某某、魏某某同原告甲银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，保证责任为连带保证责任，保证期间为主债务履行期届满之日起三年，故原告甲银行股份有限公司要求被告炊某乙、刘某某、魏某某承担连带保证责任的诉讼请求于法有据，本院予以支持。

河南省宜阳县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六百七十四条、第六百七十五条、第六百七十六条、第六百八十八条、第七百条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第一百四十七条之规定，作出判决如下：

一、限被告炊某甲、茹某某于本判决生效之日起二十日内偿还原告甲银行股份有限公司借款本金1800000元及利息439708.67元；2022年9月27日至付清之日的利息以未偿还本金为基数按年利率17.1%标准计算；

二、被告炊某乙、刘某某、魏某某对上述债务承担连带清偿责任。被告炊某乙、刘某某、魏某某承担连带保证责任偿还后，有权就偿还部分向被告炊某甲、茹某某追偿。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

在金融借款合同中，配偶方作为共同借款人加入债务应当符合“共债共签”规则，其在借款合同中的意思表示应当明确具体，如果配偶方在借款合同中仅表示“了解”或是“同意”债务人的负债，均不足以构成自愿共同负担债务的意思。只有配偶方在借款合同共同借款人处签字或明确表示愿意承担共同还款责任的，其法律地位才宜被认定为共同借款人。

一、“共债共签”意思表示应当明确具体

所谓“共债共签”规则，是指夫妻双方共同签字或事后追认，才能构成对于第三人债务承担的确认，该规则是民事法律行为意思自治原则的体现，强调

了在夫妻债务负担规则中意思表示的根本性。这一共同举债意思表示规则最早见于《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》(现已失效),该规则来源于意思自治的民法法理,即未经民事主体同意不得为其设立法律上的负担或处分其权利,该规则现已被民法典第一千零六十四条所吸收。该条第一款规定,“夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务”属于夫妻共同债务。夫妻共同债务问题,事关夫妻双方特别是未举债一方和债权人合法权益的保护,事关婚姻家庭稳定和市场交易安全的维护,因夫妻共同债务的最终责任形式为连带责任,直接影响到配偶的财产利益,故只有借款人配偶在借款合同中共同借款的意思表示必须明确、清晰,才能够根据其承诺的内容认定其在借款合同中的法律地位。

二、“知悉、同意借款事实”不符合“共债共签”的意思表示规则

“共债共签”的意思表示规则体现了对人的基本尊重,即从“夫妻捆绑主义”到夫妻各自平等独立但协作的个人主义,婚姻中个体的意志与人格应获得尊重。实践中经常存在债务人使用配偶名下的账户收付款项的情形,夫妻之间人身关系的特殊性及财产关系的混同性,使夫妻双方易于获得彼此的账户信息,因此,根据“共债共签”规则,除明确表示愿意承担共同还款责任外,在借款合同中“对转账之事知悉或同意”等不明确的意思表示不应认定配偶具备举债的合意。只有在借款合同中明确表示愿意承担共同还款责任,配偶方的法律地位才宜被认定为共同借款人。

本案中,炊某甲以个人名义向银行借款,茹某某作为配偶在借款合同的借款人配偶签名栏签字,明确表示愿意承担共同还款责任,茹某某在借款合同中的法律地位应被认定为共同借款人,共同承担还款责任。

编写人:河南省宜阳县人民法院 姚硕辉

二、银行卡纠纷

10

持卡人服刑期间其亲属的用卡行为不属于盗刷行为

—— 吴某某诉某银行信用卡中心等信用卡案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市思明区人民法院(2023)闽0203民初16717号民事判决书

2. 案由：信用卡纠纷

3. 当事人

原告：吴某某

被告：某银行信用卡中心、某银行信用卡中心厦门分中心、某银行厦门分行

【基本案情】

2013年8月22日，某银行信用卡中心向吴某某发放了尾号为7646的信用卡。该信用卡管理系统显示“是否需要消费密码：是”“是否设置交易密码：是”。《领用合约》约定：“持卡人应亲自妥善保管及谨慎使用信用卡卡片及密码，不得出借或允许他人使用、保管。”

2021年9月13日，南京市看守所作出《刑满释放证明书》，载明：“兹有

吴某某……因犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年6月17日被江苏省南京市高淳区人民法院判处有期徒刑一年二个月……（2020年7月14日至2021年9月13日）……现因执行期满，予以释放。特此证明。”

2021年3月至10月，案涉信用卡账号存在多笔逾期还款记录被个人征信报告采集。

吴某某曾于2021年10月2日拨打银行客服电话，通话过程中吴某某提到：“我有一张信用卡，是白金卡……但是我去年7月的时候就已经被逮捕了……我现在刚释放……后面出来查询到我的信用卡透支了9万多元……其间是我家人使用了……”“但是我亲戚和律师就是说代给他们保管，就给他们保管了，但是也是我在不知情的情况下我的信用卡被我弟弟刷了。”

某银行信用卡中心提交的银行流水显示，案涉信用卡在2021年3月3日至5月1日频繁存在“他行ATM取现”操作；2021年4月14日，尾号9078的账号“自助”转入案涉信用卡10200元。

吴某某称其曾就案涉信用卡报警，但经法庭询问吴某某明确表示其无法提供报警记录等证据。吴某某刑满释放后已将案涉信用卡欠款全部结清。

吴某某主张其在服刑期间客观上无法使用案涉信用卡，既无消费行为，亦无逾期还款行为，在此期间的信用卡逾期还款行为属于信用卡被盗刷的情形，由此导致的后果不应由其承担，据此诉请判令某银行厦门分行、某银行信用卡中心及其厦门分中心消除吴某某在2021年期间的不良征信记录。

某银行信用卡中心及其厦门分中心辩称，案涉信用卡并不存在技术手段的盗刷情形，系持卡人家属使用密码的正常刷卡消费行为，其按照相关法律规定上报征信记录并无不当；某银行厦门分行则辩称其与某银行信用卡中心系相互独立的法人，吴某某诉请要求其消除不良征信记录缺乏事实和法律依据。

【案件焦点】

吴某某服刑期间，其信用卡被亲属所使用的行为是否属于信用卡盗刷行为，某银行信用卡中心是否应当为持卡人消除不良征信记录。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：本案的争议焦点在于案涉不良征信记录是否应当予以消除的问题。《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》第十四条规定：“持卡人依据其对伪卡盗刷交易或者网络盗刷交易不承担或者不完全承担责任的事实，请求发卡行及时撤销相应不良征信记录的，人民法院应予支持。”本案中，吴某某与银行客服的通话录音表明，其曾将案涉银行卡交给家人代为保管，该信用卡在其服刑期间被其家人使用，从而导致产生了逾期记录。而根据《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》第十五条、第十六条的规定，伪卡盗刷交易是指他人使用伪造的银行卡刷卡进行取现、消费、转账等，导致持卡人账户发生非基于本人意思的资金减少或者透支数额增加的行为；网络盗刷交易是指他人盗取并使用持卡人的银行卡网络交易身份识别信息和交易验证信息进行网络交易，导致持卡人账户发生非因本人意思的资金减少或者透支数额增加的行为。鉴于案涉信用卡系被吴某某家人所使用，故不属于伪卡盗刷交易或网络盗刷交易。案涉《领用合约》明确约定“持卡人应亲自妥善保管及谨慎使用信用卡卡片及密码，不得出借或允许他人使用、保管”，吴某某在服刑期间虽然无法使用案涉信用卡，但仍负有妥善保管信用卡及密码的义务，其未尽妥善保管义务致案涉信用卡被家人使用，某银行信用卡中心对该信用卡的逾期记录进行采集并无不当，吴某某要求对相应不良征信记录进行消除缺乏事实和法律依据，不予支持。

福建省厦门市思明区人民法院依照《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》第十四条、第十五条、第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

驳回吴某某的全部诉讼请求。

宣判后，各方均未提出上诉，判决已发生法律效力。

【法官后语】

信用卡被盗刷，现实中主要有两种模式：一是伪卡盗刷交易，指他人通过技

术手段读取卡片信息后伪造信用卡进行取现、消费、转账等；二是无卡网络盗刷交易，指他人使用非法手段盗取卡主的身份信息和验证信息后通过网络渠道的盗刷交易。从《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》第十五条、第十六条的规定看，这两类盗刷行为的共同特点是违背持卡人本人的意思，通过伪造卡片或盗取信息，使信用卡账户金额发生持卡人本人不可控制的变动。

这里的关键问题是，如何判断“本人意思”？这是区分信用卡自用行为和盗用行为的关键。本案中，持卡人主张由于其正在服刑，故对案涉信用卡无法实际控制，其虽然将信用卡交给家属代为保管，却没有让其家属使用消费的意思表示，其家属透支案涉信用卡的行为违背了自己的真实意愿，据此主张信用卡存在盗刷行为，并诉请银行消除相应征信不良记录。

信用卡是发卡行基于持卡人的资信状况进行评估后核发的，银行凭借核对敏感信息中的一项或多项来确认使用者，如果验证信息符合，则默认信用卡系由持卡人使用。持卡人在申请信用卡时签署的《领用合约》明确规定持卡人应亲自妥善保管并谨慎使用信用卡卡片及密码，不得出借或允许他人使用、保管，该义务不因持卡人被采取刑事强制措施或服刑而消灭。

从本案查明的事实看，持卡人在服刑期间将案涉信用卡交由家属保管，在此期间，案涉信用卡不仅有支取记录，还有自助还款的记录，可见案涉信用卡系由持卡人家属实际控制并使用。分析其亲属获知密码的途径，无非有两种可能：一种是持卡人向其亲属透露了该信用卡的密码，另一种是其亲属基于对持卡人生活习惯的了解，自行推断出了密码。无论是哪种情形，持卡人均违反了《领用合约》关于亲自保管卡片及密码的约定，在此情况下可以认定持卡人对信用卡交由他人保管、密码泄露存在过错，故出现逾期记录的本质原因并非盗刷，而是未妥善保管账号密码，从这个意义上说，持卡人亲属的用卡行为并未违背持卡人本人的意思。因此，在持卡人将信用卡交给他人保管的情况下，保管人输入密码的用卡行为属于信用卡凭密码的自用行为，而不属于信用卡盗刷。正因如此，持卡人应承担由此引发的相应责任。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 张艳

持卡人主张银行卡被网络盗刷 应当就盗刷事实的存在尽到初步的举证责任

——周某某诉某银行借记卡案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2023)京74民终1847号民事判决书

2. 案由：借记卡纠纷

3. 当事人

原告：周某某

被告：某银行

【基本案情】

周某某在某银行开通了一张尾号为3292银行卡(以下简称涉案银行卡)。2018年9月7日12时46分,周某某为其涉案银行卡办理手机银行签约业务及网上银行签约业务,并申请电子密盾,绑定手机号为×××××××5763,某银行向该手机号成功发送相应短信通知。当日,涉案银行卡定期转活期收入100028.33元。2018年9月7日14时36分及14时42分,该银行账户分别向案外人陈某某尾号8500的银行账户转账5万元,合计10万元。上述两笔交易行为的IP地址显示分别为中国北京市与中国台北市。周某某在涉案争议交易发生后一直未办理银行卡挂失手续。2019年7月18日,周某某向公安机关报案,公安机关出具的《受案回执》载明2020年1月16日周某某被盗窃案已受理。此外,据某银行某支行了解,周某某与陈某某系朋友关系。

【案件焦点】

涉案争议交易行为是否构成网络盗刷。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：首先，涉案争议交易系通过手机银行转账发生，该交易一般均需经过手机银行的登录验证，转账操作时需输入短信验证码、交易密码等关键要素才可完成，上述要素均由持卡人完全掌握，部分信息银行亦无法获取。其次，涉案交易发生前后，涉案银行卡存在诸多次交易，周某某亦确认某银行发送的短信。再次，争议交易发生后，涉案银行账户项下存在诸多次交易，且交易方式多样，在此情况下周某某称其一直未发现争议交易，有悖常理。最后，结合本案中争议交易收款主体的名字、某银行酒仙桥支行提供的与周某某妻子的通话录音、《受案回执》中载明的周某某发现争议交易后向公安机关报案的时间、周某某发现争议交易后未对银行卡进行挂失的情况等诸多因素，法院认为，本案中周某某的涉案主张未能达到证明涉案交易系非本人或本人授权操作的初步证明标准。周某某仅凭涉案交易显示的IP 地址不一致的问题，亦无法达到上述证明标准。且某银行某支行在整个交易过程中正常履行了各项验证及通知义务，现有证据无法证明某银行某支行存在系统风险或安全保障能力不足等导致相关信息泄露的情形。故本院认为周某某的涉案诉讼请求无事实依据，本院不予支持。

北京市朝阳区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回原告周某某的全部诉讼请求。

周某某不服，提起上诉。北京金融法院经审理认为：同意一审裁判意见，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

相关持卡人在遭遇电信诈骗后，以被网络盗刷为由企图将相关被诈骗资金

损失转嫁银行的情况偶有发生。为妥善审理相关案件，笔者认为以下两个问题应予以重视。

首先，网络盗刷事实的认定基础在于合理分配持卡人与银行的举证责任。笔者认为目前的司法实践中，对于《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《银行卡规定》）第四条所设定的举证责任分配的理解存在一定的偏差，应予明确。首先，持卡人应对争议交易系网络盗刷交易负有初步的举证责任，只有持卡人通过对相关事实、证据的梳理初步证明相关交易确系网络盗刷交易，足以使人民法院形成存在银行卡盗刷事实的合理怀疑，才可以认定持卡人尽到了初步的举证责任，相关举证责任才会转移至银行。而目前部分案件中，持卡人在仅有报案证明及银行明细的情况下，即主张相关交易为盗刷交易，并由此主张应当由银行来举证证明相关交易系持卡人本人或本人授权交易，笔者认为该种理解有误。理由在于，如果持卡人未能提交初步的证据证明相关交易系盗刷交易，并使法官形成合理怀疑，则因相关交易本身均通过了银行卡密码或短信验证码等信息验证，其本身即应认定为持卡人本人交易或本人授权交易，此时银行不再负有进一步举证的义务，且在客观上亦难以进一步举证。

其次，涉银行卡网络盗刷纠纷中，对于盗刷事实的认定系案件审理的关键。根据《银行卡规定》第十五条，对该问题的认定至少应当包括以下两个方面：一是交易是否系网络交易。实践中该项事实较易识别，一般争议不大。二是交易是否系盗刷。不同于涉实体卡盗刷纠纷中的事实认定，网络交易中，对相关交易是否系本人操作或本人授权操作往往是案件事实认定的基础及最重要的争议焦点。对此，笔者认为可以通过争议交易明细、交易方式、交易IP地址、报警记录、挂失记录、持卡人用卡习惯以及庭审询问的事实发生细节等予以认定。考虑到目前司法实践中，持卡人偶有隐瞒被电信诈骗的事实，而主张相关交易为网络盗刷的情况，笔者认为庭审调查中对于相关交易细节进行全面、深入地询问尤为关键。具体到本案中，一方面，虽然周某某提供了涉案争议转账记录、报警记录及争议行为发生时的IP地址（指互联网协议地址）信息，但其某某未挂失涉案银行卡，亦未及时报警，且从庭审询问情况来看，其对相关交易的大量解释前后矛盾，难

以自圆其说，故虽然其提供的IP地址信息存在争议，但因实践中IP地址篡改难度较低，故仅凭IP地址亦无法证明涉案交易系网络盗刷。另一方面，涉案交易流水显示，周某某在涉案争议交易发生前后均正常将涉案银行卡用于工资收入、医保转账、日常消费等，再结合争议交易收款主体的名字及与该主体周某某的关系等辅助事实，本院认为在本案中周某某未能对涉案网络交易系盗刷发生尽到初步的举证责任。在此情况下，银行不应就争议交易承担赔偿责任。

编写人：北京市朝阳区人民法院 周裕财 熊格

12

电信诈骗中银行责任的认定

——陈某某诉某银行某分行、某银行某支行借记卡案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省温州市中级人民法院(2023)浙03民终4493号民事判决书

2. 案由：借记卡纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：陈某某

被告(被上诉人)：某银行某分行、某银行某支行

【基本案情】

陈某某在某银行某分行、某银行某支行先后开立尾号1874借记卡、尾号5101信用卡，并均开通了网上银行业务。2021年6月4日、6月7日，尾号5101信用卡账户发生两笔万利金/分期融交易，金额分别为300000元、100000元，均转入尾号1874借记卡账户。2021年6月4日至9日，尾号1874借记卡

账户发生六十余笔借贷记录，转账支出共计2737972元（其中200000元系转入陈某某他行账户），陈某某主张转出账户收款人肖某某、刘某等与其根本不相识，转账行为并非其所为，某银行未尽安全保障义务。故诉请判令：（1）某银行某支行返还万利金信用卡划扣的透支款本金400000元及利息；（2）某银行某分行支付被盗刷存款2337972元，并赔偿利息损失。

法院经审理另查明：陈某某在某银行某分行、某银行某支行先后开立尾号1874借记卡、尾号5101信用卡，签署《某银行股份有限公司个人银行账户管理协议》及《某银行股份有限公司电子渠道个人客户服务协议》，并均开通了网上银行业务，上述协议中已对相关风险进行了提示。陈某某涉案交易渠道均为超级网银，UK 数据验签+短信动态密码验证，MAC地址与6月前账户交易的MAC地址、IP地址相同。2021年6月9日17时41分，陈某某向温州市公安局鹿城区分局洪殿派出所报案，报案记录为“报警人陈某某于2021年6月1日至9日，在其家中收到自称温州市公安局的电话称其银行卡在广州市公安局侦办的一起案件中涉案。报警人添加对方QQ，下载软件，后发现银行卡内的款项被对方转走”。次日，温州市公安局鹿城区分局决定对陈某某被诈骗案立案侦查。

另查明，陈某某在申请开立尾号1874借记卡的同时签约网上银行，安全类型USB-KEY数字证书，预留手机号码135×xx×8848。某银行短信平台管理系统显示：2021年6月4日尾号1874借记卡账户向陈某某农行卡账户、肖某某账户、刘某账户转账时，短信平台均向尾号8848的手机号码发送动态密码及转账后账户余额短信息；14:37:58，短信服务被撤销；之后转账短信平台均仅向尾号8848的手机号码发送动态密码短信息（内容为“动态密码x×x×××，序号××。您将向收款人xx×，尾号xx×x账户转账x××××元。【温馨提示】转账汇款需谨慎，多方核实防被骗。请勿泄露！〔某银行〕”）。

【案件焦点】

电信诈骗案件中银行责任应如何认定。

【法院裁判要旨】

浙江省温州市鹿城区人民法院经审理认为：陈某某在某银行处申请开立银行卡，双方之间建立借记卡存款合同关系，双方均应依法行使权利并履行各自义务。首先，陈某某申请开通网上银行业务时签署的《个人银行账户管理协议》《电子渠道个人客户服务协议》中多处对借记卡、银行账号、密码、短信验证码、U盾等要素的重要性及泄露后果进行风险提示，故某银行作为发卡行已履行告知持卡人银行卡具有相关网络支付功能义务。陈某某在个人银行电子渠道专业版服务申请时勾选了网上银行（默认开通短信动态密码）、UK数字证书^①，亦应当知晓UK验证、短信验证码具有划转其账户款项的身份识别作用，陈某某作为上述要素、介质的直接保管者和使用者，负有妥善保管之合同义务。其次，根据陈某某的报案记录，案涉账户交易系不法分子通过非法手段获取陈某某信息，进而冒充公检法工作人员，以陈某某需要配合调查为由，要求陈某某添加好友并下载“某防护”APP^②，随后诱导陈某某操作并获取账户信息，从而实施诈骗，以致陈某某案涉账户资金被转移。陈某某主张仅根据诈骗分子要求下载所谓的防护APP、插入U盾即造成账户内资金全部流失，亦与该院向公安刑侦部门征询结果不符。最后，根据案涉交易的网银交易日志及转账短信验证记录，6月4日至9日陈某某所持银行卡的账户款项转账均进行了短信验证码验证与UK验证，交易时间正常，转账交易的IP地址、MAC地址^③亦与持卡人常用地址一致，故案涉交易特征并无异常。某银行在收到绑定设备和转款的交易指令后，向预留的手机号码发送短信验证码，以此进行身份验证并按照指令转款的行为，符合双方的约定，亦符合相关规定。综上，某银行根据电子银行业务的相应规则，在验证了相应关键要素之后通过并完成案涉转账交易并无过错。本案尚无充分证据证明某银行未尽安全保障义务，应对案涉转账交易的发生负有法律责任。遂判决如下：

①指一种存储设备，内置了用于网上交易的数字证书，以下不另外提示。

②指手机应用软件，以下不另外提示。

③指媒体存取控制位址，也称为局域网地址，以下不另外提示。

驳回陈某某的诉讼请求。

陈某某不服一审判决，提起上诉。

浙江省温州市中级人民法院经审理判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，随着网络技术的发展，电信诈骗案件高发，受害人发现被骗后由于难以向犯罪分子追回被骗款项，为了挽回损失往往主张经办的银行承担赔偿责任。在电信诈骗案件中银行是否需要承担民事责任，承担民事责任的依据、责任的归责原则及举证责任应如何分配在实践中亟须统一。

一、电信诈骗案件中银行承担民事责任的依据

借记卡属于典型的储蓄合同，储蓄合同具有保管合同和服务合同的属性。银行在提供账户服务的同时，实际支配了账户的存款利益。在储蓄合同关系中，银行在充分保障存款人对账户资金自由支取的权利外，还对账户存款安全负有充分保障义务。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十六条第二款规定：“电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者等违反本法规定，造成他人损害的，依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担民事责任。”《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条规定：“宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。经营者、管理者或者组织者承担补充责任后，可以向第三人追偿。”《中华人民共和国商业银行法》第六条规定：“商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。”因此，根据上述规定，因电信网络诈骗而引起的民事诉讼，法院应予受理且银行为适格的被告，银行是否应承担责任的判断标准为银行是否尽到安全保障义务。

二、电信诈骗案件中的归责原则

银行的安全保障义务属于储蓄合同的附属义务，银行违反安全保障义务属于侵权责任的范畴，应以过错责任为归责原则。在电信诈骗案件中适用过错责任原则认定侵权责任的法理基础在于：首先，互联网的发展促进了金融便利，这种金融便利让银行获得了更多合同利益，也正是这种金融便利，让电信诈骗有机可乘，但安全的法益高于金融便利和效率，若银行业存在过错，未尽安全保障义务，让银行承担一定的责任符合风险和收益相对等的原则，也能有效推动银行业对安全保障技术的有效投入，降低电信诈骗发生的概率。其次，此类案件的审理既要维护电信诈骗中受害人的合法权益，督促银行提高技术水平、改善服务，又要避免银行成为“深口袋”，影响金融安全稳定，因此，应以银行在安全保障义务方面具有过错为责任承担的前提。最后，安全保障义务责任的归责原则以过错责任为原则，亦符合民法典关于侵权责任归责原则的规定。

三、电信诈骗案件中举证责任的分配

由于在银行卡交易中，有关支付授权的所有记录和数据、录像等都掌握在发卡行等主体手中，持卡人难以获得和掌握，若按照民诉法“谁主张，谁举证”的证明责任，由持卡人对交易中银行的过错承担证明责任，这无疑加大了受害人举证责任的难度，或者说基本上就是举证不能，故应依据证据法中“谁占有证据谁举证”的举证责任分配原则，占有上述证据的主体即银行方应对其已经尽到安全保障义务提供证据加以证明，即从证明分配的公允角度而言，银行应当自证其明。申言之，法院应要求银行提供反映持卡人同意交易的形式以及动态交易监管等后台数据以证明其已尽到安全保障义务。在电信诈骗中，认定银行是否尽到安全保障义务主要应从以下几个方面考虑：银行是否为客户开通线上服务充分告知风险；U盾等网上银行支付是否存在安全漏洞，是否采取动态密码、脸谱等有效技术安保措施；银行是否依据结算合同尽到支付提示义务；银行对于用户的身份信息、个人密码等是否存在违法泄露情形；针对老年人等易被诈骗人员是否设置必要限额；等等。若有证据显示银行未尽到安全保障义务，则银行应就受害人的损失按照其过错程度承担一定比例的赔偿责任。

本案中，陈某某轻信他人下载诈骗软件，银行提供其后台的相关数据证明其已尽到安全保障义务，陈某某亦无其他相关证据证明银行违反安全保障义务，故陈某某的诉讼请求不能成立。

编写人：浙江省温州市中级人民法院 李劼

13

金融机构在电信诈骗导致的网络 盗刷交易中的责任认定 ——李某诉某银行借记卡案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省深圳市中级人民法院(2022)粤03民终19505号民事判决书

2. 案由：借记卡纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):李某

被告(上诉人):某银行

【基本案情】

李某系年逾八十的高龄老人。2012年李某在某银行开通借记卡账户及网上银行，以手机动态口令即短信验证码作为支付指令验证方式。2019年6月，李某接到“公检法”的电话，称其涉嫌犯罪要被刑事逮捕，银行账户资金需要冻结，所有银行账户资金、基金股票抛售后要转到李某在某银行的借记卡账户以备审查。李某恐惧之下，在一个月内存将1100余万元陆续转存到该借记卡账户内。

后公安机关民警来到李某家中，提醒李某可能遭遇电信网络诈骗。当晚李某让其子登录手机银行，发现登录密码错误，重置登录密码后，发现账户内仅剩35元。次日，李某向公安机关报警。因电信网络诈骗刑事案件未能破获，李某向法院提起民事诉讼，请求银行赔偿资金损失。

法院审理查明，涉案银行卡在收到李某从其他账户转账后，资金在几分钟之内被迅速转出。其中某日分69笔转出500万元后，因超出了当日限额于次日0时又多笔转出155万元。在一个月內，涉案账户共分179笔转出1100余万元，账户余额仅35元。上述交易的IP地址与MAC地址均位于外省，而在交易过程中李某未收到某银行发送的短信验证码。

某银行辩称，李某系遭遇电信网络诈骗转出资金，账户资金减少不排除本人操作或其授权操作，应由其自身承担相应后果。

【案件焦点】

1. 涉案交易能否认定为网络盗刷交易；2. 如构成网络盗刷交易，金融机构是否应当承担责任以及责任比例。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市南山区人民法院经审理认为：涉案账户的转账行为均表现出转账人意欲在账户存在余额后在最短的时间内转出全部款项的特点，与李某之前的交易习惯不符。且无证据证实李某与收款方存在基础交易，而一次性手机验证码的方式登录网银存在安全漏洞，涉案交易构成网络盗刷具有高度盖然性。某银行应当采用适当的加密技术和措施，保证电子交易数据传输的安全性与保密性，应当对交易器具、交易场所加强安全管理，对各项软硬件设施及时进行更新升级，以最大限度地防范资金交易安全漏洞。在未尽到相关安全保障义务的情况下，某银行应当对被网络盗刷的本金承担70%的赔偿责任。同时，李某在频繁使用涉案账户收取款项的情况下，没有尽到作为储户的安全注意义务，导致后续损失进一步扩大，应当自行承担30%的责任。

广东省深圳市南山区人民法院判决如下：

一、某银行应于判决生效之日起十日内向李某赔偿存款本金7805700元及利息损失(利息自2019年7月26日起按中国人民银行同期同档次存款利率计算至本金赔偿之日止);

二、驳回李某的其他诉讼请求。

某银行不服一审判决,提出上诉。广东省深圳市中级人民法院经审理认为:涉案交易存在账户资金集中转入、分散转出,快进快出、过渡性质明显,账户余额相对于交易额比例较低,长期未使用的账户突然发生频繁、大额交易,跨行收款并跨行转账等特征,符合电信诈骗可疑交易的条件。综合报警情况、交易地址、交易系统的安全性等情况,可以认定构成网络盗刷。某银行未尽到安全保障义务,包括未尽到风险告知义务,未采用安全可靠的支付指令验证方式,未进行大额交易提醒,也未进行电信网络诈骗可疑交易监测并采取核实交易情况、暂停账户非柜面业务、交易背景调查等安全防范措施,对因网络盗刷造成的资金损失承担主要责任。深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定,作出如下判决:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

电信网络诈骗犯罪作为一种远程非接触性犯罪,具有技术含量高、迷惑性强、防范难度大等特点,近年持续多发,严重侵害人民群众的财产安全和其他合法权益,引起社会高度关注。

为预防、遏制和惩治电信网络诈骗犯罪活动,第十三届全国人民代表大会常务委员会审议通过了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称反电信网络诈骗法)并于2022年12月起施行;最高人民法院也制定了《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》并自2021年5月25日起施行。反电信网络诈骗法立足综合治理、源头治理和依法治理,侧重前端防范,明确电信业务经营者、银行业金融机构和非银行支付机构、互联网服务提供者负有安全主体责任,违反相关规定,造成他人损害的,可能要承担民事责任。《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》在持卡人与发

卡行之间成立银行卡合同法律关系情形下，对因银行卡盗刷发生纠纷的银行责任认定问题，确立了无过错归责原则。适用无过错归责原则认定违约责任的法理基础在于：首先，作为银行卡产品与服务的推行者，发卡行在提供银行卡产品获得收益的同时应当以更加安全的技术保障持卡人的用卡安全，这符合制造风险者应防范风险的法理以及风险与收益相对等原则。其次，发卡行具有相较于持卡人更为强大的风险预防、控制和承受能力。规定无过错归责原则有利于鼓励发卡行提供安全性更高的银行卡产品和服务，尤其是随着电子银行业务的发展，银行既是电子交易系统的开发者、设计者、维护者，也是电子交易的获利者，相较于持卡人，银行更有能力采取措施防范风险和解决问题，从源头上降低风险发生概率，防控金融风险，促进银行卡产业安全稳定发展。最后，符合民法典关于违约责任归责原则的规定。该规定有利于减轻非违约方责任，保护非违约方利益，增强当事人的守约意识。

本案电信网络诈骗发生时，反电信网络诈骗法尚未实施，但商业银行法规定了商业银行对储户存款具有安全保障义务，《电子银行业务管理办法》《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等监管规范明确了电子银行的风险告知义务、交易系统与技术的安全保障义务、涉电信诈骗可疑交易的监测与审慎核实义务以及相应的风险控制义务。本案依据《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》，认定金融机构对账户安全负有保障义务，对网络盗刷造成的资金损失承担无过错责任；持卡人对账户安全负有注意义务，对网络盗刷造成的资金损失承担过错责任。该裁判标准符合《中华人民共和国反电信网络诈骗法》综合治理、源头治理和依法治理原则，有利于督促金融机构等各相关业务经营主体积极落实风险管理措施，加强防范性制度措施建设，深入推进行业治理，强化企业社会责任，同时也督促持卡人增强识别和防范电信网络诈骗的意识，共同筑起防范电信网络诈骗的“防火墙”。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 孙妍

金融交易合同中单方变更条款的效力认定规则

——郝某某诉某银行股份有限公司、某银行股份有限公司信用卡中心信用卡案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京金融法院(2023)京74民终1616号民事裁定书

2. 案由：信用卡纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 郝某某

被告(上诉人): 某银行股份有限公司信用卡中心(以下简称某银行信用卡中心)

被告: 某银行股份有限公司

【基本案情】

2019年8月,某银行信用卡中心官网发布“零钱包积分赚不停”活动。按照规则,持卡人向该银行零钱包账户充值达到日均存款额25万元以上,银行即向持卡人赠送积分,最高可获得180万积分。原告参加了该活动,并于2019年12月30日获赠了全部180万积分。2020年3月20日,某银行信用卡中心发布《调整积分兑换里程规则的公告》,将信用卡客户积分兑换我国航空公司里程比例由原本的25:1调整为50:1,新规在45日后生效。原告认为,某银行股份有限公司在其获得180万全部活动积分3个月后将里程兑换比例由25:1提高为50:1的做法,损害了其合法利益,且在其参加涉案活动时未尽到积分可能

贬值的风险告知和提醒义务，故将某银行及某信用卡中心诉至法院，要求其对其获赠积分继续按照25:1的兑换比例进行兑换，并免除年费及已扣除的6万积分。

某银行及某银行信用卡中心共同辩称，其已按照活动规则向郝某某赠送180万积分。零钱包活动规则中未对所赠送的积分指定用途，积分的使用规则应当以被告的《积分计划条款与细则》为准。《积分计划条款与细则》第八条规定，银行信用卡中心有权根据政策要求及市场经营情况修改或取消本积分计划，故其对积分兑换航空里程比例进行调整具有合同依据，且积分兑换规则的调整与变动属于行业惯例。

【案件焦点】

某银行股份有限公司及某银行信用卡中心是否有权利修改涉案信用卡积分兑换规则。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：涉案银行零钱包活动系以赠送积分作为最核心的营销点，且存入零钱包的款项均不计利息，故该活动开展时所确定的积分奖励计划、兑换规则及相应积分背后所蕴含的价值，对消费者是否参与该活动具有决定性的影响，属于可能影响消费者重大决策的关键信息。郝某某按照活动规则，将相应的存款转入了零钱包账户，以放弃相应存款利息，乃至丧失相应资金支配利益为代价，获得了相应的积分。其在该活动项下所获得的积分，有别于一般的因持卡人消费而获赠的积分。换言之，该积分具有一定的利息替代物及财产价值属性。郝某某作为活动参与方，对于相应积分价值具有合理的预期利益，该预期利益应予以保护。但本案中，一方面，某银行信用卡中心在开展涉案零钱包活动时，在其活动宣传界面，并未对积分到账后，其可能随时对积分兑换规则进行调整，并由此对积分价值产生重大影响等影响消费者重大决策的关键信息尽到充分的提示说明义务；另一方面，某银行信用卡中心在涉案积分全部到达郝某某积分账户仅3个月后，即行调整兑换规则，时间

间隔较为短暂，且造成涉案积分价值明显低于郝某某参与涉案活动时的合理预期。某银行股份有限公司信用卡中心涉案调整行为不具有合理性。

本案中，某银行信用卡中心制定的信用卡领用合约及其在官网发布的《积分计划条款与细则》均符合格式条款的认定标准，应被认定为格式条款。但某银行信用卡中心仅在其信用卡领用合约中对积分计划进行了名词解释，在涉案零钱包活动开展过程中，未对《积分计划条款与细则》中可能影响零钱包活动参与人利益的相关条款尽到提示说明义务。故依据《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款之规定，在涉案零钱包活动项下，《积分计划条款与细则》第八条不应成为合同的内容，某银行信用卡中心涉案调整行为不具有合同依据。

同时，某银行信用卡中心涉案调整行为，相较于一般的将积分商城中单个商品上架或下架的影响，明显更为重大，对积分价值必然产生直接影响。且某银行信用卡中心未能举证证明在其规则调整后的缓冲期内，保障了郝某某以原积分兑换比例进行航空里程兑换的合法权利，应属违约。

综上，北京市朝阳区人民法院判决如下：

一、某银行信用卡中心于本判决生效之日起45日内，针对郝某某参加某银行信用卡中心“零钱包积分赚不停”活动项下所获180万积分中剩余的154万积分，继续按照某银行信用卡中心于2020年3月20日发布《关于调整某银行积分兑换航空里程规则的公告》前的积分兑换航空里程的兑换比例，即25:1的比例进行航空里程的兑换；

二、某银行信用卡中心免除原告郝某某所持有的卡号为6226××××××××3081信用卡2021年9月6日至本判决生效之日起45日内的年费；

三、驳回郝某某的其他诉讼请求。

某银行信用卡中心不服一审判决，提出上诉。二审过程中，某银行信用卡中心撤回上诉，一审判决现已生效。

【法官后语】

目前格式合同广泛适用于金融消费、影视服务、交通出行等领域，且普遍

呈现“一对多”的特点。而格式合同的提供方为保障其随时调整合同内容的权利，往往在合同中设定“单方变更权条款”，即约定其享有单方变更合同条款，而无须相对方同意的权利。近年来，因该做法导致的消费者权益保护与合同提供方变更权之间的矛盾日益显现，本案即属于因该种矛盾引发的典型案例。目前我国民法典对于本案所涉“格式条款单方变更权”核心争议问题尚未有制度化的规定，且司法实践的认定思路及裁判尺度亦尚存不完善、不统一之处。笔者认为，本案对该问题的解决具有以下参考价值：

一是金融机构或商家对格式条款的单方变更行为，实际涉及对合同中“单方变更权条款”本身及“变更后条款”内容两个方面的审查。简言之，机构欲单方变更合同条款内容，需要同时满足两个条件，一是合同中约定合同提供方享有“单方变更权”的条款本身应当合法有效；二是合同提供方依据“单方变更权条款”所作出的“变更后条款”内容应当合法有效，二者缺一不可。

二是关于“单方变更权条款”本身是否合法有效。一方面，应当严格依照民法典第四百九十六条关于格式条款的相关法律规定进行认定；另一方面，“单方变更权条款”应符合可期待性的判断标准，即格式条款使用人负有使相对人在不持有偏见的情况下，能够准确理解，并预见可能变更的情形的义务。具体表现为对条款变更的前提、内容、方式等应尽量明确具体。类似于“认为必要时可以变更”等表述方式可能被认定无法满足可期待性原则。比如本案中某银行信用卡中心在条款中约定其行使修改权的前提是“政策要求”及“市场经营情况”，其中“市场经营情况”明显过于宽泛，可能给合同相对方造成极大的不安定，且存在银行借此转移经营风险的嫌疑，该种“单方变更权条款”即有可能被认定不具有可期待性，进而被认定为无效。

三是关于“变更后条款”是否合法有效。该问题包括实体及程序两个方面。实体上，应当考虑变更后条款的内容是否“符合相对人的一般利益及预期”及“合理性”两项标准。例如本案中，郝某某对于银行设定的积分奖励及适用规则明显具有合理的预期利益，银行不应随意更改。同时，合理性问题还应当重点考察相关条款的变更原因、条件、后果、目的、是否损害另一方的合

法权益、相关业务是否具备特殊性等因素。例如本案中，原告因参加“零钱包”活动获得的积分具有特殊性，而银行基于其与航空公司之间的合作变化及获取航空里程的成本增加等原因，随意调整积分兑换规则，具有重大的转嫁商业风险之嫌，不具有合理性。

程序上，欲使“变更后条款”内容产生效力，也必须将该变更后的条款内容以合理、有效的方式送达相对方，而对于送达方式的选择，则可结合被送达对象的规模、送达成本、困难程度及变更内容的实质影响等因素综合认定。例如本案中，银行对于其变更的内容，仅通过官网进行发布，实际上对于持卡人获知规则变更内容以及在合理期间内行使权利均亦是不利的。

编写人：北京市朝阳区人民法院 周裕财

跨境消费中信用卡预授权后超额结算的司法审查

—— 余某诉某银行信用卡中心信用卡案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市浦东新区人民法院(2022)沪0115民初30608号民事判决书

2. 案由：信用卡纠纷

3. 当事人

原告：余某

被告：某银行信用卡中心

【基本案情】

2019年10月，余某与朋友一行赴A国旅游。2019年10月28日，为入住

酒店，余某持尾号8674的信用卡在酒店刷卡交易6000A国货币用于支付酒店房间入住押金。2019年10月31日下午，余某收到某银行信用卡中心电话询问一笔交易的真实性，余某予以否认。其后，某银行信用卡中心以可疑交易需要核对为由对余某的信用卡进行保护，余某随后办理信用卡挂失。2019年11月2日，某银行信用卡中心在余某信用卡账户中入账45000A国货币。2019年11月7日，余某与某银行信用卡中心客服人员电话协商系争事宜。余某表示酒店住宿费用已经通过其他方式支付，某银行信用卡中心客服人员询问了具体交易过程，并表示需要余某提供酒店订单详情等材料以便反馈沟通。2019年11月8日，余某与某银行信用卡中心客服人员电话协商，客服人员告知余某没有酒店入住信息，仍需进一步完善。2019年11月13日，余某与某银行信用卡中心客服人员电话协商，某银行信用卡中心表示余某提供的截图中的付款方式是隐藏的，建议提供原图。某银行称根据万事达卡组织退单指引 (mc-Chargeback Guide)，以其他方式支付进行拒付必须提供详尽的支持文档，余某无法提交有效的支持材料，未能进行后续拒付处理。

余某认为A国酒店住宿费用已通过其他方式支付，发生45000A国货币交易时余某不在现场且未经本人签字，该笔交易系被他人盗刷，某银行信用卡中心在余某否认交易的情况下仍然进行入账清算明显存在过错，应当向余某退还45000A国货币。

【案件焦点】

1. 案涉交易是否为盗刷；2. 在余某不在场且已否认交易的情况下，某银行信用卡中心将系争交易清算入账是否存在过错；3. 余某是否有权要求某银行信用卡中心退还系争款项。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：关于本案交易是否为盗刷，本案中，余某认可6000A国货币的授权交易系本人实施，发卡行亦提交了卡组织授权记录 and 核心系统入账记录，载明后续45000A国货币的交易系基于同一授权号的

请款交易产生，故法院对余某盗刷的主张不予支持。

关于在余某不在场且已否认交易的情况下，某银行信用卡中心将系争交易清算入账是否存在过错的问题，本案中，在发生异常交易后，余某及时否认交易并挂失，某银行信用卡中心及时提醒余某并调整卡片状态，双方均采取了必要的风险管控措施。至于系争的45000A国货币交易最终清算入账，某银行信用卡中心解释为系挂失前的正常6000A国货币授权交易的后续请款行为所致，根据万事达卡组织规则，请款金额可以与授权金额不一致，某银行信用卡中心作为发卡行无权拒绝请款清算。法院认为，某银行信用卡中心方的解释具有一定的合理性，且提供了相应证据在案佐证，余某虽然不予认可，但未举证证明某银行信用卡中心的清算入账行为违反了合同约定或万事达卡组织相关清算规则，在银行卡组织提供了事后争议解决和申请退单渠道的情况下，法院认定某银行信用卡中心清算入账系争交易的行为不存在明显过错。

在系争交易未能成功退单的情况下，某银行信用卡中心是否负有赔偿责任。从国际信用卡管理运营的通常情况来看，发生信用卡争议交易并不鲜见，争议发生后持卡人、发卡行、收单行、特约商户等各方可通过卡组织的争议解决机制申请进行退单等操作。在这一过程中，发卡行应负责积极申请处理以维护持卡人合法权益，持卡人亦应积极配合调查并提供必要的证明材料。本案系争交易发生后，某银行信用卡中心多次要求余某提供证明材料以供核查，余某虽提供了部分单据，但单据所载商户名称与系争信用卡交易商户名称不一致，部分单据信息被隐藏，且未提交其他证据予以佐证，在此情况下，某银行信用卡中心未能成功完成退单操作，难言其存在违约或侵权行为。

综上，上海市浦东新区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》第四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回原告余某的全部诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

跨境预授权交易作为信用卡的特殊业务形式，为持卡人的境外消费带来便利，但因其与普通的信用卡交易方式不同，持卡人对跨境预授权存在交易授权与资金清算不同步、预计消费金额与实际结算金额不一致的特点缺乏充分认知，导致司法实践中争议频发。本案系预授权交易纠纷的典型案件，预授权的法律性质、发卡行的责任认定及持卡人权益保护均是审理中的难点。本案根据国内法律规定及国际信用卡组织规则，就上述问题进行了较为系统深入的剖析，尤其是跨境预授权的超额结算问题，并确立了涉预授权信用卡纠纷的审查路径。

一、信用卡预授权视为发卡银行对特约商户的付款承诺

信用卡预授权是指基于持卡人与特约商户之间的基础交易关系和持卡人的信息确认及同意授权，发卡行对持卡人预计可能支付的金额向特约商户作出付款承诺。这一过程涉及三层法律关系：一是信用卡持卡人与发卡行之间的服务合同关系是预授权交易的前提要件；二是信用卡持卡人与特约商户之间的基础交易关系是发生预授权交易的原因关系，预授权虽源于基础交易关系，但其一旦设立后即具有相当的独立性；三是发卡行与特约商户之间独立的担保付款关系是上述前提关系与原因关系的结果和目的。^①基于上述法律关系，预授权交易可以视为发卡银行对特约商户作出的付款承诺，该承诺一经作出，信用卡预授权即告设立，成为独立的法律关系。

本案中，余某在某银行信用卡中心处申办信用卡一张，其在境外旅游时为入住A国当地酒店，使用该信用卡在酒店商户刷卡6000A国货币的联机授权交易，用于办理酒店房间的入住，本案诉讼过程中，某银行信用卡中心陈述此时发卡系统仅是冻结余某信用卡账户6000A国货币的额度，并未真正入账。余某的授权交易及某银行信用卡中心冻结额度的行为符合预授权交易的法律特征，在余某刷卡当日，某银行信用卡中心其向入住的A国酒店作出付款承诺，发卡行与特约商户之间的担保付款关系成立。

^①王一鹤：《论信用卡预授权的法律性质及持卡人保护》，载《暨南学报(哲学社会科学版)》2015年第5期。

二、发卡行及持卡人需遵循国际信用卡组织交易关于超限额度的规则

持卡人境外消费时的复杂资金清算过程离不开国际信用卡组织的参与。当前，在信用卡跨境支付与清算问题缺少统一规则的情况下，国际信用卡组织的会员银行应当遵守国际卡组织规则。对金融消费者而言，不同的卡组织有相应的支付清算渠道及收费标准，在选择办理境外消费的信用卡时，应当赋予消费者完全自主选择的权利，一旦消费者确认选择某卡组织的信用卡，应视为持卡人接受该国际信用卡组织的相应规则。

信用卡领域中持卡人超出信用卡授予额度的使用是国际惯例。一般来说，中国银联设置的预授权交易完成的最高限度为持卡人信用卡账户内被冻结额度的115%，而国际信用卡组织如万事达组织规则约定“请款交易中，原始金额可能与持卡人在授权请求交易中的原始金额不同”。预授权设立时，持卡人与特约商户仅是对将来之服务达成合同准入的约定，尚未确定最终结算金额或债务种类，因此，在预授权交易结算时，最终结算金额可能超过预授权设立时冻结的额度，且超过的范围需要遵循持卡人信用卡所属的国际卡组织规则。本案中，余某所持有的系万事达信用卡，其在A国酒店进行预授权设立的冻结额度为6000A国货币，最终结算45000A国货币，并未超过万事达国际组织规则的限制。

三、发卡行根据预授权及卡组织请款指令清算不构成侵权

预授权设立后，持卡人否认交易发生认为构成盗刷，并据此向发卡行申请挂失止付，发卡行在此情况下仍然依据预授权及卡组织的请款指令进行交易清算是否构成侵权成为当前司法实践的难点。对此，本案从预授权与信用卡盗刷的区别、挂失状态能否对此预授权结算两个角度明确裁判路径：

第一，预授权交易与信用卡盗刷的本质区别为是否被第三方冒用。预授权交易的完成存在预授权设立与预授权结算两个关键环节，具有预授权担保的合同准入与最终的实际清算环节不同步、冻结额度存在超额结算可能性两个特点。因发卡行的承诺与结算存在时滞性，持卡人在完成消费后的一段时间内均可能收到信用卡账单，该消费入账当日持卡人可能不在现场也未签字，但该交易清

算与预授权设立属于同一授权，持卡人的签字或密码确认并非预授权结算的必要步骤，因而与信用卡盗刷具有实质区别，不存在被第三方冒用的可能性。本案中，发生45000A国货币交易并入账时，余某本人虽不在现场且未签字，但发卡行提交的相关材料证明45000A国货币与6000A国货币的交易系基于同一授权号的请款交易产生，故本案不存在盗刷。

第二，挂失信用卡原则上不能对抗预授权结算。持卡人挂失信用卡后能否对抗预授权结算实际反映了发卡行能否自行撤销预授权的问题。就预授权交易的独立担保性质而言，发卡行作出的付款承诺应当是不可撤销之担保，信用卡挂失状态原则上不影响预授权结算的效力。即使持卡人的信用卡账户在预授权结算前就已在挂失状态，发卡行仍然应当履行其对特约商户的付款承诺，发卡行根据预授权及卡组织请款指令清算不构成对持卡人的侵权。本案中，持卡人余某在系争交易发生后即向发卡行办理了挂失手续，但挂失后仍不能阻却45000A国货币以预授权结算方式入账。

四、持卡人在预授权争议解决机制中应履行证明义务

当发生跨境信用卡纠纷时，当事人自主协商解决不成的，发卡行应当协助持卡人在国际卡组织规则约定的时限范围内发起流程内争议解决流程，且持卡人应当遵循卡组织的规则，承担其理应履行的证明义务，有效提供卡组织所需的支持材料，如持卡人应当证明已就预授权交易所依据的基础交易履行了支付义务，提供持卡人或其他人的支付凭证、预授权确认单、结算单等材料。若持卡人在规定的时间内未能提交有效证明材料，应当承担相应的不利后果。本案中，余某主张其在A国酒店的住宿费已通过网络支付，某银行信用卡中心告知余某可在120日内发起争议和退单，后因余某未能提供符合要求的证明材料，最终未在规定时间内通过退单程序解决争议。

此外，持卡人合法权益保护还有赖于发卡行对持卡人知情权的保障，考虑到当前信用卡境外消费的普及性，如维萨、万事达等国际信用卡组织的规则在消费者境外用卡时使用的频率较高，发卡行应向持卡人披露国际信用卡组织关

于预授权的相关信息，如预授权的授权期限、超限额度及异议处理方式等。^①本案中，法院虽最终判决驳回余某的诉讼请求，但也对持卡人的知情权进行了提示。

编写人：上海市浦东新区人民法院 余韬 刘月

16

网络盗刷银行卡案件的举证责任分配

——王某某诉某银行某支行借记卡案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江西省赣州市中级人民法院(2023)赣07民终593号民事判决书

2. 案由：借记卡纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王某某

被告(上诉人):某银行某支行

第三人：某公司分公司

【基本案情】

2019年7月29日，王某某在某银行某支行申请办理了一张借记卡，卡号尾号为6572。原告开立该卡时，一并开通了个人网上银行、个人电话银行、个人手机银行及短信银行等服务业务，但未开通银行短信通知功能。借记卡章程第一条载明：某银行借记卡是某银行发行的金融支付工具，具有结算、消费、

^①参见何颖：《金融消费者权益保护制度》，北京大学出版社2011年版，第66页。

理财等全部或部分功能，不提供透支业务；借记卡在中华人民共和国境内及其他指定的国家和地区使用。

2019年11月12日，原告的案涉借记卡收到转存的款项20万元，同年11月20日，该借记卡被刷卡消费了48381.22元，当月24日，原告通过手机银行查询发现案涉借记卡被刷卡消费48381.22元后立即打电话给被告对案涉借记卡进行了口头挂失。同年11月25日，原告在其父母的陪同下一起前往被告的营业部，就案涉借记卡被刷卡消费一事造成的损失与被告交涉未果。原告遂至赣州某派出所报警，认为其借记卡存款系被人盗刷，但该派出所并未对案涉借记卡是否存在被盗刷作出立案处理。

另查明：某公司分公司提供的司法查询结果及银行卡交易明细查询显示：2021年11月20日08时24分40秒原告的案涉借记卡发起消费交易，同日08时25分48秒中国银联股份有限公司向原告发送了付款验证码，同日08时25分50秒原告收到付款验证码，08时26分07秒原告的验证码验证成功，08时26分12秒原告的案涉借记卡扣款成功。

【案件焦点】

案涉交易能否认定为盗刷，举证责任如何分配。

【法院裁判要旨】

江西省赣州市章贡区人民法院经审理认为：对于案涉借记卡是否被盗刷的问题，原告通过查询发现案涉借记卡被刷卡消费后立即打电话给被告对借记卡进行了口头挂失，第二天原告与被告交涉无果后，又至公安机关作报案处理。虽然公安机关未对案涉借记卡是否存在被人盗刷进行立案处理，但依据原告提供的接处警记录及银行交易明细清单，原告已完成了相应的举证责任，且被告不能举证证明原告作为持卡人存在故意或过失泄露借记卡信息或密码导致借记卡被盗刷，故在对于案涉借记卡原告并不存在遗失以及被告不能证明原告对其银行卡、密码、验证码等身份信息、交易验证信息未妥善保管具有过错的情况下，应当由被告承担举证不能的法律后果，认定原告借记卡被刷卡消费系被他

人盗刷所致。对于原告借记卡被盗刷所造成的损失承担问题，被告作为专业金融机构应对原告卡内的资金负有保障存款安全以及对银行卡信息防盗技术及识别伪卡技术的责任。在现有证据不能证明原告存在过错导致卡内资金被盗刷的情况下，被告应对案涉银行卡被盗刷所造成的损失承担相应的赔偿责任。对被告就本案提出的抗辩意见，本院不予采纳。据此，江西省赣州市赣区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条，《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》第四条、第七条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、某银行某支行于本判决生效之日起七日内向原告赔付银行卡本金损失**48381.22元**；二、某银行某支行于本判决生效之日起七日内赔付王某某损失银行卡本金的利息(以损失银行卡本金**48381.22元**为基数，自**2019年11月20日**起至该本金损失赔付完毕止，按中国人民银行规定的同期活期存款利率支付利息)。

某银行某支行不服，提起上诉。

江西省赣州市中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点问题归纳为：第一，案涉交易能否认定为盗刷；第二，某银行某支行是否应向王某某赔偿**48381.22元**及利息。

关于争议焦点一，依据《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》第六条规定：人民法院应当全面审查当事人提交的证据，结合银行卡交易行为地与真卡所在地的距离、持卡人是否进行了基础交易、交易时间和报警时间、持卡人用卡习惯、银行卡被盗刷的次数及频率、交易系统、技术和设备是否具有安全性等事实，综合判断是否存在伪卡盗刷交易或者网络盗刷交易。在本案中，首先，从交易次数和金额来看，案涉银行卡于**2019年11月20日**发生一笔**48381.22元**的交易后，此时卡内仍有余额**151626.28元**，直至**2019年11月24日**王某某对案涉借记卡进行口头挂失，在此期间未再发生交易；其次，从查明的资金流向来看，案涉交易的收单机构为某支付网络有限公司，交易类型为消费，商户名称为“The Cards Group Ltd”，交易渠道为个人电

脑；最后，从交易方式来看，案涉交易的付款方式为卡号+验证码，而王某某本人确实在2021年11月20日08时25分50秒收到付款验证码，随后才发生案涉交易。综合考虑案涉交易时间、报警时间、银行卡交易的次数及频率、交易系统、技术是否具备安全性等因素，根据民事证据的经验法则和高度盖然性标准，本院对被上诉人关于案涉交易系盗刷的主张不予支持。

关于争议焦点二，银行作为金融机构，确应当采取适当的加密措施和适当的技术、识别与验证使用电子银行服务客户的真实、有效身份，但保障金融交易和账户资金安全的义务，不应当全部依赖、转嫁给银行，根据权利义务相一致原则，在银行不断优化系统安全防护、加大系统技术支持力度的同时，持卡人也应当对个人银行账户尽到力所能及的审慎管理义务。因根据现查明的事实难以认定案涉交易系盗刷，王某某要求某银行某支行赔偿48381.22元及利息缺乏事实和法律依据，应予驳回。

江西省赣州市中级人民法院经审理判决：

- 一、撤销一审判决；
- 二、驳回王某某的诉讼请求。

王某某不服二审判决，提起再审。

江西省高级人民法院经审理判决：驳回申请人王某某的再审申请。

【法官后语】

所谓网络盗刷，是指他人冒用持卡人名义，使用持卡人网络交易身份认证信息进行网络交易，导致持卡人银行卡账户资金减少或者透支金额增加的行为。不同于传统支付方式，网络支付不需要银行卡这一物理介质，仅凭银行卡号、密码等身份验证信息即可完成交易，因此，在网络盗刷银行卡案件的审理中，存在事实查明难、过错认定难及责任分担难的问题。

一、网络盗刷事实举证责任分配的分歧

在数据关联紧密的大数据时代，网上银行在依赖互联网提供服务和产品的同时，大量的信息和资金均以数据形式通过网络与设备进行存储及传输，实现

网上银行安全保障义务首先需要保证信息安全系统和数据信息不被侵害。^①目前，在司法实践中，关于是否存在网络盗刷事实举证责任的分配，主要存在以下分歧：有的法院根据“谁主张，谁举证”原则，交易密码只为持卡人知悉、修改和保管，持卡人无法举证证明是银行过错导致银行卡被盗刷的，则由其承担举证不能的法律后果，应由持卡人承担全部损失；有的法院根据《电子银行业务管理办法》第八十九条的规定，在银行无法举证证明系持卡人原因导致资金损失及自身系统不存在安全缺陷的情况下，应由银行承担全部损失；有的法院则是在双方均无法举证证明对方存在过错的情况下，综合考虑双方当事人的合同义务，依据公平原则由双方按一定比例分担损失。

二、网络盗刷事实举证责任的分配路径

在传统银行卡盗刷案件中，其争议焦点主要集中在是否存在伪卡，持卡人可以通过举证交易发生时真卡不在交易地点来完成对银行存在过错的举证，而在网络盗刷银行卡案件中，其争议焦点有两点：一是非授权交易是否系网络盗刷？二是网络盗刷行为的发生是何原因所致？是电子银行系统存在安全隐患、金融机构内部违规操作或其他非客户原因所致，还是持卡人有意泄露交易密码，或者未按照服务协议尽到应尽的安全防范与保密义务所致？因网上支付行为不需要银行卡这一物理介质且涉及技术问题，仅凭银行卡号、密码等身份验证信息即可完成交易，在此种情况下，举证责任的分配应聚焦以下两方面：

对于持卡人而言，需就以下几个方面进行举证：(1)是否开通了网络支付业务；(2)是否妥善保管银行卡信息、密码等；(3)是否收到验证码及采取相应措施；(4)案涉交易特征是否显著异常(异常时间、异地异国、多人次)；(5)网络交易IP地址是否与持卡人常用地址一致；(6)持卡人知晓案涉交易后如何行为(是否挂失或冻结止付、报案等)。

对于发卡银行而言，需就以下几个方面进行举证：(1)是否开通了网络支付业务；(2)是否进行风险提示与告知；(3)案涉交易发生时是否发送验证码

^①李晗：《大数据时代网上银行的信息安全保障义务研究》，载《法学杂志》2021年第4期。

验证或及时提醒与通知；(4)是否存在其他异常交易实为授权交易的情形；(5)是否监控异常交易；(6)发生异常交易时是否采取防范或应对措施；(7)接到持卡人反映异常交易时是否告知冻结或采取冻结止付措施。

概言之，持卡人与银行的举证应贯穿网络支付业务开通——网络支付行为发生——网络支付行为发生后全过程。法院应综合考察上述证据，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小进行判断，依据高度盖然性标准来认定是否构成网络盗刷事实。^①

在本案中，首先，从交易次数和金额来看，案涉银行卡于2019年11月20日发生一笔48381.22元的交易后，此时卡内仍有余额151626.28元，直至2019年11月24日王某某对案涉借记卡进行口头挂失，在此期间未再发生交易；其次，从查明的资金流向来看，案涉交易的收单机构为某支付网络有限公司，交易类型为消费，商户名称为“The Cards Group Ltd”，交易渠道为个人电脑；最后，从交易方式来看，案涉交易的付款方式为卡号+验证码，而王某某本人确实在2021年11月20日08时25分50秒收到付款验证码，随后才发生案涉交易。综合考虑案涉交易时间、报警时间、银行卡交易的次数及频率、交易系统、技术是否具备安全性等因素，根据民事证据的经验法则和高度盖然性标准，对于案涉交易系盗刷的事实不予认定。

三、银行安全保障义务的审查路径

对于银行安全保障义务标准的确定，需要综合考虑风险的大小、风险控制的可能性、风险控制人的能力、受害人自我保护的能力和危害结果的严重性等因素，对具体的个案形成合理的安全保障义务标准。网上银行具有风险大、技术依赖强和专业性强的特点，用户的信息保障很大程度上依赖于网上银行自身的安全保障技术和格式合同约定等。网上银行由于本身的专业性和在信息收集、保护中占有的优势地位，承担的安全保障义务应当超过一般理性人应该具有的审慎义务，即网上银行的注意义务不是在危害结果预见和危害结果控制这两种义务中平衡分配，而是应该更新自身的安全技术，随时监控、排查，做到更优

^①张雪煤：《银行卡网上盗刷的责任认定》，载《法律适用(司法案例)》2017年第18期。

先地预见到风险的存在，主动排查危险。当网上银行尽到了这种注意义务时，即为履行了安全保障义务。①本案中，银行作为金融机构，已采取适当的加密措施和适当的技术、识别与验证使用电子银行服务客户的真实、有效身份，已尽到安全保障义务。且根据现已查明的事实难以认定案涉交易系盗刷，故王某某要求某银行某支行赔偿48381.22元及利息缺乏事实和法律依据。

编写人：江西省赣州市中级人民法院 徐俊 葛文

江西省赣州市章贡区人民法院 李晓霞

17

为避税提起虚假诉讼，法院应不许撤诉并驳回诉请和予以罚款

—— 孙某某诉某银行小关支行银行卡案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市朝阳区人民法院(2022)京0105民初57839号民事判决书

2. 案由：银行卡纠纷

3. 当事人

原告：孙某某

被告：某银行小关支行

【基本案情】

2016年，孙某某为在国外购买房产，委托一家国外贷款中介机构申请银行贷款。贷款申请材料包含国内某公司为孙某某出具的收入证明、工资表、利润

①刘召成：《安全保障义务的扩展适用与违法性判断标准的发展》，载《法学》2014年第5期。

表、现金流量表、资产负债表以及五个国内招行账户交易明细表。此后，贷款申请获得通过。2019年9月17日，国外税务机关向孙某某发送了调查问卷，因可能涉及补税，故要求孙某某就其在贷款时提交的国内银行账户交易明细表相关的银行卡补充提交开户信息。为证明交易明细不存在从而达到避税的目的，孙某某要求该银行提供其在某银行小关支行并不存在银行交易明细的证明，遭其拒绝。孙某某认为，作为持卡人应当依法享有索取该卡相关信息材料的权利，亦享有合法的知情权，而某银行小关支行拒不提供该卡相关信息材料的行为已构成严重违约，侵犯其合法权益，故将国内某银行小关支行诉至北京市朝阳区人民法院，要求银行履行合同义务，向孙某某提供银行卡签订协议、该卡使用说明资料、该卡自办理后至今的对账服务资料等相关信息。

庭前会议中某银行小关支行代理人表示，孙某某未在银行开立账户，其银行交易明细并非银行出具。对此，孙某某亦承认银行账户交易明细为虚假材料，但坚持认为银行应向其出具交易明细表所示交易实际不存在的证明材料。

庭前会议后，孙某某向法院提出撤诉申请。

【案件焦点】

1. 孙某某的撤诉申请是否应当准许；2. 孙某某与某银行小关支行是否存在合同关系；3. 对孙某某明知银行账户交易明细等均为虚假材料仍然提起诉讼的行为应如何处理。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：孙某某未说明合理理由而申请撤诉，故对其撤诉申请不予准许。关于孙某某提供的交易明细表，某银行小关支行对该证据的真实性不予认可，孙某某亦自认上述交易明细表系由贷款中介公司伪造，故双方不存在合同关系。《中华人民共和国民法典》第七条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”本案中，从来源角度看，中介机构取得该类银行卡材料的途径仅可能为孙某某提供、孙某某授权查询以及孙某某授意或者默许贷款中介机构伪造，在上述途径下孙某某都

应对此明确知悉；从使用角度看，孙某某对向贷款银行提供的贷款申请材料亦应知悉并对真实性负责。换言之，孙某某在提起本次诉讼之前便已知道《某银行户口交易明细表》为虚假材料，但为达到由某银行小关支行证明该账户不存在从而免除向国外税务局补缴税款的目的，执意提起本次诉讼，其行为直接损害了当事人合法权益，妨害了正常的民事诉讼秩序，严重违背了诚实信用原则，与社会主义核心价值观相悖，应当予以谴责。

北京市朝阳区人民法院判决如下：

驳回孙某某的诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

一、虚假诉讼的概念和类型

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十五条的规定，虚假诉讼既包括当事人之间恶意串通的情形，也包括当事人单方捏造事实的情形，而本案就是一起“单方捏造型”的虚假诉讼，孙某某凭伪造的银行交易明细表将某银行小关支行诉至法院，企图达到自己的不当目的，妨害了银行的经营秩序，也浪费了司法资源。

二、“单方捏造型”虚假诉讼的识别

“单方捏造型”虚假诉讼的识别重点与相对更为常见的“双方串通型”虚假诉讼有一定区别，可以从以下三个方面入手：

第一，穷尽送达方式，重视抗辩意见。因“单方捏造型”虚假诉讼不存在双方恶意串通的情形，被告一旦获悉诉讼情况将提出强烈抗辩，故对于原告对未送达成功毫不意外，反而积极要求法院公告送达的，需要保持高度警惕。被告的抗辩意见将成为法院查明原告诉讼请求真实性的突破口，若被告在抗辩意见中提出原告存在虚假诉讼行为，法院应当予以重点审查。

第二，审查交易背景，探寻诉讼目的。法院应充分利用法庭询问的机会，了解深层背景信息，注意识别原告的陈述能否形成完整的逻辑闭环，能否对不合理之处进行合理说明。

第三，传唤原告本人到庭，接受法庭询问。虚假诉讼的原告本人通常会因为担心“露馅”而选择不出现在审判人员和对方当事人面前。在缺乏对方当事人配合的情况下，诉讼代理人往往对无法解释的内容闪烁其词，继续追问则表示自己现在不清楚，需要庭后与原告本人核实。针对存在虚假诉讼嫌疑的案件，应当传唤原告本人到庭接受法庭询问，以各种理由拒绝到现场的，可以通过当庭拨打电话并记入庭审笔录的方式进行询问。

三、虚假诉讼不准许撤诉的正当性

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款规定：“宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十八条第一款规定：“当事人申请撤诉或者依法可以按撤诉处理的案件，如果当事人有违反法律的行为需要依法处理的，人民法院可以不准许撤诉或者不按撤诉处理。”孙某某在庭前会议后自知虚假诉讼行为暴露，申请撤诉，但其向法院提交的撤诉申请书中未明确撤诉的原因，企图通过撤回起诉后，更换立案法院，再行提起诉讼的方式达到其不法目的，故法院不准许其撤诉。

四、对虚假诉讼的处罚

打击和预防虚假诉讼一直以来都是人民法院的一个重大课题。惩罚力度不足、违法成本不高是目前惩治虚假诉讼工作中面临的问题之一，以本案为例，即便未能达成目的，此次虚假诉讼行为的违法成本也仅为70元诉讼费。实践中，“低成本、高收益”的特征使得许多人铤而走险，虚假诉讼案件屡禁不止。因此，必须加大虚假诉讼的处罚力度，对主观恶意明显、客观危害性较大的虚假诉讼行为，通过司法制裁、移交公安机关等手段予以严厉打击，从而起到更好的震慑效果。

编写人：北京市朝阳区人民法院 李林强 于一帆

信用卡被盗刷的法律适用及 刑事退赃与民事赔偿之间的衔接

—— 宋某某诉某银行股份有限公司信用卡中心信用卡案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海金融法院(2023)沪74民终2309号民事判决书

2. 案由：信用卡纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 宋某某

被告(上诉人): 某银行股份有限公司信用卡中心

【基本案情】

2017年6月28日, 宋某某在某银行股份有限公司信用卡中心(以下简称某银行)处申领了一张卡号尾号为0939的信用卡。领用合约第2.4.2条约定: “凡因交易性质或习惯, 并按甲方规定或依乙方选择不使用密码的交易……经密码或验证要素校验通过, 交易即视为乙方本人所为并由乙方承担交易款项。特约商户、收单机构或甲方核验乙方签名, 按行业通行的一般识别标准执行。” 第五条第一款约定: “乙方应遵守甲方关于安全用卡的各项规定, 采取所有合理谨慎措施, 妥善保管信用卡, 以及身份证件、交易凭证和甲方不时向乙方发送的卡函、对账单等文件, 防止可能被用作验证乙方身份或确认交易的各项信息(包括但不限于验证要素和各种密码、个人私密信息、信用卡交易信息以及指纹等个人生物特征信息)丢失或泄露。” 第五条第二款约定: “乙方发生信用

卡遗失、被盗或被他人占有，或密码遗忘、泄露等情形的，应立即通过客服热线、电子银行或甲方认可的其他方式办理挂失或密码重置手续。挂失和密码重置自甲方办理完毕时生效；但乙方仍应对挂失生效前已发生的或密码重置生效前凭原密码已进行的所有交易（包括尚未入账的交易），以及挂失生效后发生的电子现金脱机消费承担全部责任。”《信用卡重要提示》第二条约定：“为加强用卡安全，推荐设定交易密码，并在适用的场合尽可能使用密码交易确认方式。”

被告于2018年4月开始报送涉案信用卡的不良征信记录，原告提交的《个人信用报告》显示，原告于2018年4月逾期9765元，2018年5月逾期16487元，2018年6月逾期24691元，2018年7月逾期47927元，2018年8月逾期48605元，2018年9月逾期49316元，2018年10月逾期50037元，2018年11月逾期50746元，2018年12月逾期51491元，此后2019年1月至2021年5月每月的状态均为：“账户已开立，但当月状态未知。”自2021年6月起，被告继续报送原告的不良征信记录，2021年6月逾期76366元，此后不良征信记录一直持续至2023年2月，逾期金额逐渐增加。

2018年9月21日，山西省临汾市尧都区人民法院作出（2018）晋1002刑初429号刑事判决，刑事判决经审理查明：2017年12月17日凌晨，田某某伙同李某某来到酒店停车场，田某某将原告的晋x×x黑色奔驰轿车右后玻璃砸毁，由田某某望风李某某钻进原告车内，将原告车内的现金500元及银行卡包盗走，后该二人逃窜至李某某住处，田某某根据原告的身份证试出密码后，用POS机将盗来的原告的10余张银行卡内的钱分20余次盗刷出55200元。刑事判决认为，田某某以非法占有为目的，盗窃他人财物价值70776元，李某某以非法占有为目的，盗窃他人财物价值90776元，其行为已构成盗窃罪，判处田某某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年五个月，责令田某某、李某某向被害人宋某某退赔赃款。审理中，原告确认未收到该二人的任何退赔款项，承办法官经与山西省临汾市尧都区人民法院执行法官沟通，对方对原告的陈述予以确认。

涉案信用卡消费记录显示，2017年12月17日凌晨4点01分至凌晨5点51分，涉案信用卡共计消费17笔，金额共计42200元，为此原告提供了上述17笔消费的POS 签购单，签购单中持卡人签名均为“李某”。后原告于2017年12月17日10点45分致电被告要求挂失涉案信用卡。同日，原告向临汾市公安局经济技术开发区分局报案，2017年12月18日12时，临汾市公安局经济技术开发区分局出具立案告知书，对原告银行卡内钱被盗刷一案予以立案。2017年12月18日15点45分，原告拨打被告电话要求补办新卡，被告为其核发了新卡（卡号：622×××7）。

2018年1月11日，原告通过电子邮件向被告客户服务部申请交易异议处理，提供否认交易声明，并提交相应资料。同日，被告对原告提出异议的16笔消费记录进行了消费代调。2018年1月12日，原告填写《贷记卡客户否认交易确认函》，确认尾号0939的信用卡账单中的16笔交易合计42000元，为非本人或本人授权他人使用。审理中，原告解释其仅对16笔交易提出异议的原因系其遗漏了一笔交易，其提交异议的交易总计应为17笔。后因交易争议失败，被告于2017年1月25日对原告争议的16笔消费进行了消费借调。

另，被告提供的涉案信用卡消费记录显示，截至2017年12月16日，涉案信用卡余额为0.02元，未存在透支款项。2017年12月17日凌晨4点01分至凌晨5点51分，产生涉案争议消费17笔共计42200元。2017年12月18日产生补发新卡工本费15元（该笔工本费的到期还款日为2018年1月15日，因原告未还款，故于2018年1月21日账单日产生违约金10元）；2018年1月18日产生消费38999元，2018年1月22日原告还款4482元；2018年2月14日原告还款35271元；2019年2月13日原告分别还款100元和1900元。

【案件焦点】

涉案信用卡被盗刷产生的损失应当如何承担。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：确定信用卡被盗刷产生的损失如何

承担，应结合各方的过错程度加以认定。就本案而言，宋某某持有的涉案尾号0939的信用卡被盗刷非原告宋某某未妥善保管所致。被告辩称原告未设置POS机刷卡密码，然而根据《信用卡申请表》，“设定交易密码”仅为双方约定的推荐内容，持卡人可以选择设置或不设置交易密码，不能据此苛责原告承担相应的不利后果。本案中，宋某某在信用卡被盗刷后的当天即办理了信用卡挂失，并向公安机关报案，可以证明原告采取了其可以采取的相关积极措施，以避免涉案信用卡损失的产生或防止损失的进一步扩大，故难以认定宋某某对涉案信用卡的损失发生具有相应过错。

反观涉案信用卡被盗刷的过程，涉案17笔消费POS签购单中的签名与信用卡持卡人姓名明显不一致，对此被告辩称，签名审核是特约商户的义务，而非被告的义务，特约商户的过错责任不应由被告承担。然而信用卡交易过程涉及发卡行、收单行以及特约商户等多方主体，多方主体均应履行各自的义务来促成交易的安全进行。被告作为发卡行，负有采取安全合适的措施确认银行卡交易为持卡人本人或其授权交易的义务。根据原告提供的消费POS签购单，持卡人签名与信用卡持卡人姓名明显不一致，故法院难以认定被告在确认涉案17笔消费为原告本人或其授权交易时尽到了审慎审核的义务，由此产生的损失应由被告自行承担，其承担责任后可以依法向存在过错的收单行或特约商户另行主张。关于被告提出根据《信用卡领用合约》，信用卡被盗挂失生效前发生的所有交易产生的损失应由原告自行承担的意见，法院认为根据上述约定的文义，该条款调整的内容为持卡人对使用其真实的身份识别信息和交易验证信息产生的交易的责任承担问题，无论该条款的效力如何，均不适用于本案，本案情形属于发卡行未能审慎审核持卡人的身份识别信息和交易验证信息，上述约定并不能免除发卡行在确认交易为原告本人或其授权交易时的审核义务，被告依据该条款提出的抗辩意见，法院难以采纳。综上，原告对涉案信用卡被盗刷款项及由此产生的相应违约金、利息不承担还款责任。

此外，虽刑事判决判令案外人田某某等向原告退赔包括涉案信用卡被盗刷在内的赃款。但原告尚未收到任何退赔款项，其不应承担涉案信用卡项下的还

款责任，故若今后原告收到刑事判决中的任何退赔款项，应当及时将收到的款项全部转付至被告。

对于原告提出撤销其不良征信记录的诉请，法院认为，征信系统功能在于通过收集信用信息数据对被记录者的真实信用进行评价，从而引导社会对被记录者凭其信用参与其他社会活动形成公平、正确的反馈。在被记录者对其还款义务提出重大质疑并已提供证据的情况下，其暂不还款的行为系行使抗辩权利而非信用缺失的体现，应有别于一般的失信行为，不应因此而遭受不良征信之记录。本案原告虽在客观上存在逾期还款的记录，但在双方当事人就原告是否负有还款义务存在重大争议，尚未认定当事人各自应承担的法律责任之前，原告对系争款项暂不还款的行为，并非失信的体现，应当将该失信记载及时加以纠正，否则将对原告的个人信用形成错误的评价。综上，上海市浦东新区人民法院根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十一条之规定，判决如下：

一、确认宋某某对涉案信用卡(原卡号：622×××9,新卡号：622×××7)项下于2017年12月17日凌晨4时01分至凌晨5时51分产生的17笔争议消费共计42200元以及由此产生的相应利息、违约金不承担还款责任；

二、某银行股份有限公司信用卡中心应于本判决生效之日起十日内撤销宋某某名下卡号为622×××7的某银行信用卡不良征信记录。

某银行股份有限公司信用卡中心不服一审判决，提出上诉。上海市金融法院经审理同意一审意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，因信用卡被盗刷引起的民事和刑事案件呈上升趋势。在持卡人作为受害人的信用卡盗刷刑事案件中，刑事判决一般判处犯罪分子将盗刷赃款退还至持卡人处，同时发卡行与持卡人产生民事纠纷，由发卡行起诉要求持卡人归还逾期款项或持卡人起诉发卡行主张对被盗刷的款项不承担还款责任以及撤

销不良征信记录。对于该类案件还款责任的认定，司法实践中存在较大争议。

本案有两个问题值得关注和探讨，其一，真卡被盗刷的法律适用及盗刷责任认定；其二，刑事判决赃款退还至持卡人与持卡人对发卡行的还款责任如何衔接。

对于第一个问题，《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》对伪卡盗刷及网络盗刷进行了明确规定，伪卡盗刷强调他人持伪造的银行卡进行盗刷，网络盗刷则强调他人通过使用持卡人的银行网络交易身份信息和交易验证信息等进行网络交易，而真卡被盗刷虽在外观形式上与二者有区别，但其本质都是非因持卡人主观意思表示发生银行卡被盗刷的结果，故在认定盗刷责任时可以参照适用《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》。本案中，《信用卡领用合约》中关于在信用卡被盗刷，持卡人对挂失生效前的所有交易承担全部责任的约定，根据《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》，银行仅得主张持卡人未妥善保管密码或未及时挂失的减损、免损抗辩，因此，该约定属于不合理减轻或免除己方责任、加重对方责任的格式条款，不具有法律效力。

对于第二个问题，发卡行负有保障持卡人资金安全、交易安全的法定义务，而持卡人应当合理审慎保管信用卡及密码。在信用卡盗刷事实成立的情况下，除非发卡行举证证明其尽到了安全保障、信息提示等法定义务，被盗刷系持卡人不规范使用信用卡等原因所致，否则银行应当承担信用卡被盗刷的损失后果。在持卡人作为受害者对信用卡被盗刷无过错的刑事案件中，即便刑事判决判处犯罪分子将赃款退还至持卡人处，从现实情况看，刑事退赃由于犯罪分子退赃意愿及退赃经济能力等因素的制约，持卡人是否能够得到退赔以及退赔的时间及具体金额也并不确定，在持卡人尚未收到犯罪分子退赔的情况下，若在民事纠纷中判令持卡人将被盗刷款返还至发卡行处，则会出现应当由发卡行承担的法律风险转由持卡人承担，发卡行与持卡人之间的权利义务出现失衡。对此，人民法院在审理此类信用卡民事案件时，应当实质审查刑事案件的执行情况，确定持卡人是否获得退赔以及退赔的金额，若持卡人已经实际获得部分或全部

刑事赔偿，则人民法院应当判决持卡人将此款项归还至发卡行；若持卡人尚未获得刑事赔偿，人民法院应当驳回发卡行请求持卡人归还款项的诉请，并在说理部分对持卡人获得赔偿后的还款责任进行说明。

综上，本案确立了真卡盗刷的法律适用及信用卡盗刷刑事退赔与民事赔偿衔接的裁判思路，依法衡平持卡人与发卡行之间的权利义务，判决支持持卡人的合理诉求，对类案的审理及保护持卡人的合法权益具有一定的参考借鉴意义。

编写人：上海市浦东新区人民法院 孙猛 王晓雷

以第三人实施欺诈为由主张撤销合同的司法审查要点

——秦某诉某银行北京分行信用卡案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2023)京74民终332号民事判决书

2. 案由：信用卡纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 秦某

被告(被上诉人): 某银行北京分行

【基本案情】

2022年3月3日，秦某与某银行北京分行签订信用卡业务合同，约定：信用卡分期业务本金219000元，按逐期等额方式分摊至60期偿还，一期为一个月，若秦某未能全面履行按时足额偿还分期债务的义务，则构成违约，某银行北京分行可向金融信用信息基础数据库、银行业协会报送秦某违约的失信信息，

并且授权相关银行业协会可以通过适宜的方式将秦某的失信信息在银行业金融机构之间共享乃至向社会公示。2022年3月4日，某银行北京分行向秦某在合同中预留的银行账户发放款项219000元。后贷款发生逾期，秦某个人征信记录中被记载了涉案借款的违约信息。

秦某称，其系在案外人李某、贷款中介公司及某银行北京分行客户经理串通欺诈才签订的涉案合同，相关贷款均由李某使用，故要求确认合同无效并删除其不良征信记录。

北京市公安局朝阳分局于2022年6月29日决定对秦某被诈骗案立案侦查，于2022年7月11日将李某拘留，后因人民检察院做出不批准逮捕决定，于2022年8月17日将李某释放，并于2022年8月18日对李某采取取保候审措施，对案件继续进行侦查。

在公安机关的笔录中，李某和秦某均承认双方此前为情侣关系后分手，李某称2022年2月底，其因欠付外债需要贷款，但因个人征信不好故求助秦某帮其贷款。秦某其称未仔细看与贷款中介公司及银行所签的贷款资料就签字了，以为只是帮李某提升征信分值，后某银行北京分行催收后才知道李某用自己的名字申请了贷款并已逾期，产生了不良征信记录。

某银行北京分行否认与李某或贷款中介公司串通欺诈秦某。在某银行北京分行提交的贷款面签视频中，秦某回答已确认是本人申请贷款并知晓还款事项。

【案件焦点】

1.秦某是否系基于李某的欺诈行为与某银行北京分行签订涉案信用卡业务合同；2.秦某是否有权以李某对其存在欺诈为由要求撤销涉案信用卡业务合同或确认该合同无效。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：无论李某是否构成诈骗罪，涉案信用卡业务合同系在秦某与某银行北京分行之间订立。秦某提交的证据尚不足以证明某银行北京分行工作人员与李某恶意串通的事实，某银行北京分行与秦某订

立信用卡业务合同的过程中，充分履行了告知、说明义务，秦某作为具有完全民事行为能力在经济理性人，应当注意对自身征信信息等个人信息的保护，亦应当清楚其在银行办理相应业务的法律后果将由其自行承担，现其主张信用卡业务合同无效，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

关于秦某要求某银行北京分行清除其不良征信记录的请求，根据《征信业管理条例》的规定，秦某发生信用卡逾期还款的情形时，某银行北京分行有义务向金融信用信息基础数据库报送相关信息。信用卡业务合同中亦约定，在秦某发生违约时，某银行北京分行有权向金融信用信息基础数据库报送相关信息。故本院对秦某的该项请求不予支持。北京市朝阳区人民法院判决如下：

驳回秦某的全部诉讼请求。

秦某不服一审判决，提起上诉。

北京金融法院经审理认为：秦某与某银行北京分行签订信用卡业务合同，应按合同约定的用途和方式使用信用卡分期资金，并依约按时足额偿还分期业务本金和手续费。秦某称某银行北京分行工作人员与李某恶意串通，但其提交的证据不足以证明其主张的事实。

北京金融法院同意一审法院的审理意见，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一百四十九条规定，第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

本案中，秦某以案外人李某与某银行工作人员串通，共同对其实施欺诈，致使其陷入错误认识，方与某银行北京分行签订涉案信用卡业务合同为由，要求确认该合同无效。因撤销合同与确认合同无效的法律后果均是导致该合同自始不发生法律效力，而经过开庭审理可知，无论主张无效还是撤销，秦某的请求都无法得到支持，故未释明秦某变更诉讼请求。但本案的审理对于明确以第三人实施欺诈为由主张撤销合同的审查标准仍具有典型意义。

第一，要以存在第三人实施的欺诈行为为前提。所谓“第三人”，必须是合同相对人以外的人。如果是合同相对人或者其他与合同相对人存在密切关系的人实施欺诈，则不属于本条规定的适用范围，应适用相对人欺诈的法律规定。

本案中，根据李某在公安机关所做询问笔录中的自认，李某向秦某称系李某贷款，贷款由李某偿还，找秦某帮忙是为了提升李某的征信分值，只需要秦某配合签字并提供账号即可，但最终贷款系以秦某的名义办理，秦某需承担还款义务，显然李某对秦某实施了欺诈。李某并非合同相对人，与作为合同相对人的某银行北京分行亦不存在其他密切的关系，故构成第三人实施欺诈。

第二，欺诈行为与受欺诈一方实施的法律行为存在因果关系。受欺诈一方系因第三人的欺诈才实施了相关民事法律行为，如果没有第三人实施的欺诈行为，受欺诈方就不会实施该民事法律行为。

本案中，李某的欺骗导致秦某陷入错误认识，秦某基于此种错误认识与某银行北京分行签订了涉案信用卡业务合同。若无李某的欺诈行为，秦某根本不会签订涉案信用卡业务合同，该合同并非秦某的真实意思表示，秦某签约的行为与李某的欺诈行为存在直接和充分的因果关系。

第三，法律行为相对人知道或者应当知道受欺诈一方是因为受到第三人的欺诈才实施了该法律行为，即相对人非善意，这也是合同相对人不具有信赖利益保护价值的原因。

本案中，秦某主张某银行北京分行工作人员与李某串通欺诈秦某，若秦某主张的事实成立，那么“串通”的程度自然要高于“知道或者应当知道”，将足以认定某银行北京分行作为相对人为非善意，或直接认定其存在恶意，进而撤销涉案信用卡业务合同。但关于相对人非善意的举证责任在受欺诈一方，因秦某在本案中未能完成该项举证责任，故法律规定的第三人实施欺诈进而导致合同可撤销的要件未具备，某银行北京分行的信赖利益应予以保护，涉案信用卡业务合同不具有可撤销性。

第四，以第三人实施欺诈为由主张撤销合同并不要求受欺诈一方无过错。在受第三人欺诈而实施法律行为的情形下，受欺诈一方往往都存在轻信他人、

不注意保护个人信息、未尽到谨慎交易的注意义务等过错。根据民法典的规定，第三人欺诈导致法律行为可撤销并不要求受欺诈方存在过错。审判实践中，受欺诈一方的过错程度将会影响最终责任比例的划分或损失赔偿数额的认定，受欺诈一方存在明显过错的，可能需要自行承担部分损失。

编写人：北京市朝阳区人民法院 赵靓 乔楠

银行卡伪卡盗刷案件中发卡行责任的认定与处理

—— 李某某诉某银行银行卡案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省铜鼓县人民法院(2023)赣0926民初499号民事判决书

2. 案由：银行卡纠纷

3. 当事人

原告：李某某

被告：某银行

【基本案情】

李某某系某银行的储户，持有卡号尾号为1384的银行卡一张。2023年1月24日，李某某发现银行卡中的存款丢失后向铜鼓县公安局刑警大队报案，根据公安机关调查发现，2022年10月30日至2023年1月2日，李某某所持有的账户在广东省汕头市的多个ATM机^①多次取现和转账，经调取取款银行网点及

^①指自动取款机。

周边路面监控，发现取款人员均佩戴头盔、手套、口罩，身体及面部特征均无法识别，手持用于转账或取现的印有“VIP”字样的蓝色卡片，交通工具为一辆无法识别车牌的电动车，无法识别操作取款人员身份信息。李某某被盗刷存款本金共计146900元，并产生取款手续费70元，李某某遂诉至法院，要求某银行赔偿损失。

【案件焦点】

在银行卡盗刷事实认定的情况下，某银行在合同履行过程中错误支付款项造成李某某损失，根据现有证据又无法确定李某某存在泄露信息等直接过错的，某银行的责任如何认定。

【法院裁判要旨】

江西省铜鼓县人民法院经审理认为：银行卡的发卡行及相关技术、设备和操作平台的提供者，应当对交易机具、交易场所加强安全管理，对各项软硬件设施及时更新升级，以最大限度地防范资金交易安全漏洞。李某某将存款存入发卡行后，即失去了对存款的控制，某银行作为储蓄机构，有义务保护储户存款的安全。而ATM机未能辨别真卡、伪卡，以致李某某持有的银行卡上的146900元被他人取走，并产生手续费70元。某银行认为李某某没有及时将磁条银行卡更换成芯片银行卡存在过错，芯片银行卡的安全性能较磁条银行卡更高，但中国人民银行及某银行均通过公告方式告知广大储蓄用户更换磁条银行卡，被告在公告中强调“存量磁条卡仍可继续使用”，既然某银行默许磁条银行卡可继续使用，就应对储户账户资金尽到安全保障义务。现李某某的银行卡被他人盗刷，某银行应当承担全部赔偿责任。故江西省铜鼓县人民法院判决如下：

由某银行于判决生效后十日内向李某某支付存款本金及手续费合计146970元。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

本案在审理过程中对于处理方式存在两种分歧意见：一是合同法思路，以发卡行与持卡人的银行卡合同为基本依据，以合同通常理念构建事实认定范畴与论证体系，考察双方当事人的履约事实及过错状态，根据双方过错大小认定责任。二是证券规则思路，以银行卡的资格证券性质为逻辑起点，查明事实时只判断权利人识别是否有误，确认盗刷责任时只考察发卡行是否有过错，根据发卡行识别权利人错误的结果认定责任。本案采纳第一种意见。

一、银行卡伪卡盗刷的归责模式

银行卡盗刷归责应把握以下特殊性：其一，盗刷责任主要是发卡行识别错误的赔偿责任，需要经过当事人履约事实来判断责任归属。其二，银行卡的一次支付往往要通过多个主体环节，因此归责时要根据业务链形成原因，先确定责任端，再确定责任环节。对于持卡人占有卡的原因，义务人通常无权审核，接受支付指令者无能力审核，持卡人通常也不允许其被审核，责任端往往就在发卡行一边。其三，持卡人过错是必须考量的因素，《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《银行卡规定》）第七条也持此观点。

二、伪卡盗刷责任认定的基本逻辑处理

（一）不能机械推定持卡人泄密

持卡人是否泄密极难证明，应脱离其具体行为进行推定，在违法犯罪人有预谋的情况下，持卡人较难防范，对于银行卡信息的泄露并无明显过错，不能机械推定系持卡人对泄密存在过错。本案中，违法犯罪人手持印有“VIP”字样的蓝色卡片即完成了盗刷，无法直接推定持卡人有泄密的行为，也无法排除发卡行泄密的可能。

（二）持卡人泄密与发卡行识别错误之间应具有法律上的因果关系

即使持卡人存在泄密的情形，也无法直接论证其未妥善保管银行卡相关信息泄密是导致发卡行识别错误的原因从而具有法律上的因果关系。此外，《银行卡规定》也确定了端点责任，即由发卡行一端对持卡人一端先行承担赔偿责任

任。根据该法第十一条的规定，发生伪卡盗刷时持卡人可直接请求发卡行等承担赔偿责任。

（三）发卡行的抗风险能力和社会责任相对更大

从双方当事人抵御风险的能力以及所应当承担的社会责任方面来看，相对于持卡人，发卡行处于更加优势的地位，抵御风险的能力更强，也应当承担更多的社会责任。而且从长远考虑，银行势必要升级系统、提高安全保障技术，通过判决由银行承担责任也能够推动银行防伪技术的升级进步。本案中，某银行及被告均通过公告方式告知广大储蓄用户更换磁条银行卡，被告在公告中强调“存量磁条卡仍可继续使用”，但磁条卡仍然被盗刷，更能说明被告安全保障技术的不足。

综上，在银行卡盗刷事实认定的情况下，发卡行在合同履行过程中未尽到安全保障义务错误支付款项造成持卡人损失，又未提供证据证明盗刷损失系持卡人违反信息妥善保管等义务造成，仅以持卡人未及时更换其倡议的高安全性卡或者存在泄密可能为由主张减免赔偿责任的，人民法院不予支持。

编写人：江西省铜鼓县人民法院 柯书盛 吴丽红

三、融资租赁合同纠纷

21

融资租赁出租人自行收回并处置租赁物的，因可归责于出租人事由造成租赁物价值贬损，出租人应承担不利后果

_____某融资租赁公司诉钟某某融资租赁合同纠纷案

【案件基本信息】

- 1. 裁判文书字号
福建省厦门市思明区人民法院(2023)闽0203民初16568号民事判决书
- 2. 案由：融资租赁合同纠纷
- 3. 当事人
原告：某融资租赁公司
被告：钟某某

【基本案情】

2019年5月18日，某融资租赁公司与钟某某签订《融资租赁合同》，约定：某融资租赁公司根据钟某某的选择购买汽车一辆并出租给钟某某使用，租赁物出售(转让)价款115000元；融资总额157068元，租赁期限36个月，租金4363元/月，租赁保证金9200元；承租人未能按照本合同的约定按期足额支付首期款、租金、垫付款和其他应付款项(包括双方约定的与本合同或租赁物

全部相关联的欠款),经催告后在合理期限内仍未履行时,出租人可以自行或者委托第三人立即通知承租人或其继承人解除本合同,并收回、处分租赁物件;提前收回全部租金,承租人立即支付合同项下所有租金及其他应付款项(含已经到期但未支付的租金和未到期租金,本合同项下所约定的违约金等);承租人按时足额支付租金及其他应付款项、留购价格,租赁期限届满租赁物归承租人所有。

合同签订当日,租赁物完成交付。2019年10月25日,钟某某逾期支付租金 $4363\text{元/期} \times 32\text{期} = 139616\text{元}$ (某融资租赁公司确认已经收取案涉合同项下的前四期租金合计17452元)。2019年10月28日,某融资租赁公司回收租赁物。2020年4月7日,某融资租赁公司将租赁物出售,得款86000元。

某融资租赁公司诉请:(1)确认《融资租赁合同》于2019年10月28日解除;(2)钟某某向某融资租赁公司赔偿损失44416元。

【案件焦点】

1.合同解除的时间如何认定;2.某融资租赁公司的损失如何计算。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为:某融资租赁公司与钟某某成立合法有效的融资租赁关系。因钟某某欠付租金,某融资租赁公司诉请解除合同并要求钟某某赔偿损失,符合法律规定及合同约定,可予支持。本案的争议焦点为解除时间及损失金额。

关于合同之解除。钟某某未能依约支付租金,某融资租赁公司依约有权解除合同,收回租赁物。某融资租赁公司主张以收回租赁物的方式通知解除合同,且已实际收回租赁物,可视为回收之日为合同解除通知到达之日,故法院对2019年10月28日为合同解除之日予以确认。

关于损失之计算。根据《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条第二款的规定,损失赔偿范围为承租人全部未付租金及其他费用与收回租赁物价值的差额。某融资租赁公司主张的损失为全部

未付租金139616元-保证金9200元-车辆处置款86000元=44416元，对此，法院认为，某融资租赁公司于2019年10月28日回收租赁物，但迟至2020年4月7日方才以86000元的价格将该租赁物售与他人，某融资租赁公司处置租赁物时间延后，钟某某归还租赁物后的价值贬损不应由其个人承担。2019年5月18日至2020年4月7日案涉租赁车辆在二手市场的价格贬值约为 $(115000\text{元}-86000\text{元})\div 325\text{天}=89.23\text{元/天}$ ，某融资租赁公司直到2020年4月7日才处置租赁物，距2019年10月28日钟某某归还车辆已经过162日，此期间的价值贬损 $89.23\text{元/天}\times 162\text{天}=14455\text{元}$ 应由某融资租赁公司自行承担。据此，某融资租赁公司的损失应为139616元-86000元-14455元=39161元。某融资租赁公司自愿在赔偿损失范围内扣除保证金9200元，系对自身权利的处分，法院予以照准，故扣除保证金后钟某某应赔偿的损失金额为29961元。某融资租赁公司请求钟某某赔偿损失的金额，在法院核定范围内予以支持，超出部分，不予支持。故判决如下：

一、确认某融资租赁公司与钟某某签订的《融资租赁合同》于2019年10月28日解除；

二、钟某某应于本判决生效之日起十日内赔偿某融资租赁公司损失29961元；

三、驳回某融资租赁公司的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

融资租赁是一种贸易与信贷相结合，融资与融物合一的交易模式。本案出租人与承租人成立合法有效的融资租赁合同关系。在承租人欠付租金且经催告后在合理期限内仍不支付的情况下，出租人可以请求支付全部租金，也可以解除合同，收回租赁物。本案出租人选择行使合同解除权，收回租赁物，并主张承租人赔偿损失。

1.出租人损失之认定，应先行清算。根据《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条的规定，损失赔偿范围=承租

人全部未付租金+其他费用-收回租赁物价值。应考虑到,该公式计算结果可能为正值、负值或0。因此,该公式计算的不仅是出租人所受损失,当计算结果为负值时,所计算的实际上也是出租人领受的超出合同正常履行情况下本可获得利益之外的额外利益。合同约定租赁期限届满租赁物归承租人所有时,出租人所享有的权益为租金债权,承租人已支付的租金不仅包括租赁物的使用对价,亦包括租赁物购买成本及合理利润的分摊对价。此时,融资租赁物实际上是担保财产,出租人并不当然享有收回租赁物的价值。因此,在出租人收回租赁物并处置后,应就主债权(租金债权)与担保财产(收回的租赁物)之间的价值进行清算,实行“多退少补”。若承租人全部未付租金+其他费用-收回租赁物价值=正值,则出租人有权向承租人请求损失赔偿;若为负值,则代表收回租赁物的价值超过租金债权,出租人就超额领受部分构成不当得利,承租人有权请求返还;若为0,则收回租赁物的价值与租金债权相当,出租人领受收回租赁物的价值后,租金债权因抵销而消灭。

2. 清算的难点在于收回租赁物价值的认定。收回租赁物价值的认定是损失得以正确清算的基础,因此经常成为当事人的争议焦点。收回租赁物价值可以通过融资租赁合同约定、约定的租赁物折旧以及合同到期后租赁物的残值、有资质的机构评估或者拍卖等方式确定。出租人自行收回并处置租赁物的,应对其处置程序的公平性及处置价格的合理性承担举证责任。本案出租人作为专业的融资租赁公司,且车辆作为常见的融资租赁物,根据常情常理及市场交易习惯,出租人知道或者应当知道二手车贬值快的特点。出租人处置租赁物时间延后、怠于处置或处置不当,致使租赁物价值贬损的,出租人应对贬损价值承担责任。

综上,司法裁判中,无论是计算出出租人所受损失还是计算出出租人超额领受金额,均应先行清算。清算的核心是收回租赁物价值的认定。确定收回租赁物价值时,重点审查租赁物价值是否合理、是否贬损及贬损的原因。出租人自行收回并处置租赁物的,因可归责于出租人事由造成租赁物价值贬损,出租人应承担不利后果。

本案判决为类案处理提供了新思路，对融资租赁公司也起到规范引导作用。融资租赁公司应完善合同条款，提高合规意识，在收回租赁物后，作为租赁物的实际控制人、管理人、处置人，应善尽义务，公平、及时、合理地处置租赁物。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 林秋虹

22

融资租赁公司从事融资担保的合同效力

——某融资租赁公司诉翁某某、某物流公司追偿权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市浦东新区人民法院(2023)沪0115民初3971号民事判决书

2. 案由：追偿权纠纷

3. 当事人

原告：某融资租赁公司

被告：翁某某、某物流公司

【基本案情】

2019年9月26日，翁某某与某银行签订《某银行个人网络贷款借款及担保额度合同》《某银行个人额度借款支用单》，约定借款人为翁某某，贷款人为某银行，借款金额为560000元，期限为36个月，年利率为8%，罚息年利率为12%，并约定还款方式、违约责任等。同日，某银行向翁某某发放贷款56万元。

2019年9月24日，某融资租赁公司与某银行、案外人叶某签订《最高额

保证合同》，约定为翁某某在与某银行在2019年9月26日至2022年9月24日签订的所有主合同项下的债权本金最高余额560000元的各笔债权提供连带保证责任。同日，某融资租赁公司向某银行出具《担保承诺函》。

2019年9月26日，某融资租赁公司与翁某某签订《借款担保服务合同》，约定由某融资租赁公司为翁某某的前述借款向某银行提供担保服务，某融资租赁公司为翁某某提供的担保内容、担保费用和保证金等合同主要内容均存在空白。同日，某融资租赁公司与翁某某、某物流公司签订《借款反担保合同》，约定某物流公司作为某融资租赁公司为翁某某担保的反担保，承担连带保证责任。某物流公司出具了《公司股东会决议》。

2022年7月12日，因翁某某未能按时偿还借款，某融资租赁公司向某银行支付本金149457.37元、利息4572.47元和罚息3408.57元，共计157438.41元。次日，某银行出具《代偿证明》载明，2021年12月20日该笔贷款逾期后，担保人某融资租赁公司代偿本息总金额合计157438.41元。

庭审中，某融资租赁公司自认其曾于2019年9月27日向翁某某收取过保证金56000元和服务费6750元，共计62750元；某融资租赁公司确认《借款反担保合同》为《借款担保服务合同》的从合同，若《借款反担保合同》无效，则向某物流公司主张不超过翁某某不能清偿部分三分之一的赔偿责任。

【案件焦点】

1. 某融资租赁公司与翁某某签署的《借款担保服务合同》是否有效；
2. 某融资租赁公司向翁某某追偿的范围。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：针对第一项争议焦点，首先，某融资租赁公司为翁某某的借款提供担保，应认定为融资担保，某融资租赁公司与翁某某签署的《借款担保服务合同》属于从事融资担保业务。其次，某融资租赁公司在未经监管部门批准的情况下，从事融资担保业务，违反了《融资担保公司监督管理条例》的强制性规定。最后，因某融资租赁公司违反行政法规的

强制性规定，故其与翁某某签署的《借款担保服务合同》无效。

针对第二项争议焦点，首先，某融资租赁公司基于《借款担保服务合同》收取的翁某某的62750元，应当返还翁某某。其次，某融资租赁公司与某银行签署《最高额保证合同》并在翁某某违约后代其清偿的157438.41元，应当返还某融资租赁公司。最后，因双方互负返还义务，应进行清算。关于资金占用费，应以双方各自占有对方资金的期间，按照一年期LPR计算。某融资租赁公司收取翁某某的费用后至2022年7月12日代偿翁某某欠款时的资金占用费为7459.93元。因翁某某需向某融资租赁公司返还的金额大于某融资租赁公司应向翁某某返还的金额，抵扣后，翁某某还应向某融资租赁公司返还87228.48元以及自2022年7月13日起至实际清偿之日止的资金占用费。

上海市浦东新区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条、第一百五十七条、第三百八十八条规定，判决如下：

一、翁某某应返还某融资租赁公司87228.48元；

二、翁某某应返还某融资租赁公司自2022年7月13日起至实际偿付之日止的资金占用费用；

三、某物流公司对翁某某上述第一项至第二项返还义务不能清偿部分的四分之一承担赔偿责任，被告某物流公司履行赔偿责任后，有权向翁某某追偿。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

助贷业务是指助贷机构通过自有系统或渠道筛选目标客群，在完成自有风控流程后，将较为优质的客户输送给持牌金融机构、类金融机构，经持牌金融机构、类金融机构风控终审后，完成发放贷款的一种业务。助贷机构一定程度上解决了中小微企业“融资难”的问题，但由于服务环节的增加，存在以各种名目违规收取高额费用的情况，未能彻底解决“融资贵”的问题。部分融资租赁公司作为助贷机构，除充当信息中介外，还会以自身或其关联企业为借款人提供担保，以提高借款人的还款能力，并向借款人收取相应服务费。融资租赁公司作为地方金融机构，其经营范围包含“租赁交易咨询和担保”，其从事融

资担保业务的合同性质存在争议。

一、融资担保属于特许经营

担保分为融资担保和非融资担保，融资担保包括借款类担保、发行债券担保和其他融资担保，非融资担保包括诉讼保全担保、履约担保及其他非融资担保。借款类担保，是指担保人为被担保人贷款、互联网借贷、融资租赁、商业保理、票据承兑、信用证等债务融资提供担保的行为。目前，七类地方金融组织中，仅对于融资担保公司的监管文件层级均属于行政法规，其他六类地方金融组织的监管文件层级属于部门规章或规范性文件。《融资担保公司监督管理条例》规定，未经监督管理部门批准，任何单位和个人不得经营融资担保业务。因此，融资担保属于特许经营。

二、融资租赁公司不得从事融资担保业务

《融资租赁公司监督管理暂行办法》明确了融资租赁公司的经营范围，包括“租赁交易咨询”，而部分融资租赁公司的经营范围为“租赁交易咨询和担保”。从字面意思看，该表述有两种意思，一种为租赁交易担保，另一种为租赁担保，但无论是哪种含义均属于履约担保，均无法解释为融资担保。退一步讲，如果经营范围需要批准，即使营业执照已经登记，亦不能免除批准程序。综上，在未获得监管部门许可经营融资担保业务的情形下，融资租赁公司不得经营融资担保业务。

因此，融资租赁公司为金融消费者的借款提供担保，应认定为融资担保，其与金融消费者签署相关担保服务合同的行为属于从事融资担保业务。融资租赁公司在未经监管部门批准的情况下，从事融资担保业务，违反了行政法规的强制性规定，故助贷机构与金融消费者签署的相关担保服务合同无效。

三、助贷机构从事融资担保业务的风险

包括融资租赁公司在内的助贷机构从事融资担保业务实质上提供增信或者“兜底”时，发放贷款的金融机构存在不承担或少承担的信用风险，部分风险控制措施形同虚设；而助贷机构囿于自身业务水平，存在内控管理不到位、业务流程不健全、资金用途监测不到位等问题，当出现资金断裂难以代偿或受让

债权时，风险将直接传导给银行等资金提供方，易引发系统性金融风险。

因此，明确不具有融资担保资质的助贷机构从事融资担保业务的行为无效，并判令助贷机构返还收取的费用及资金占用费，将规范助贷市场，指引助贷机构回归提供信息中介服务主业，这对于切实降低融资成本，维护金融消费者合法权益具有重要意义；此外，对于未获金融监管部门许可的助贷机构从事相关金融交易予以否定性评价，体现了与金融监管之间的协同治理，对于维护金融借款市场秩序，防范化解金融风险具有指引意义。

编写人：上海市浦东新区人民法院 顾权 王朝辉

融资租赁关系被否定后附属抵押合同的效力认定

——某融资租赁公司诉某进出口公司等破产债权确认案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海金融法院(2024)沪74民终341号民事判决书

2. 案由：破产债权确认纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某融资租赁公司

被告(上诉人):某进出口公司

被告:某饭店管理公司、茹某

第三人:某财税管理合伙企业

【基本案情】

2019年4月24日，原告与被告某饭店管理公司订立《融资租赁合同(售

后回租)》，约定被告某饭店管理公司将其所有的一批设备，包括690套淋浴设备、272套平面移动类停车设备、25套中央空调出售给原告，并从原告处租回使用；出租人向承租人交付租赁物的方式为占有改定，承租人签署《所有权转移确认书》即视为出租人已交付租赁物。合同另约定了上述设备的转让价款及租期、租金金额等内容；原告与被告某饭店管理公司签订《所有权转让协议》《所有权转移确认书》。同日，原告与被告茹某签订《保证函》，约定被告茹某对案涉《融资租赁合同(售后回租)》项下被告某饭店管理公司所负债务承担不可撤销的连带责任保证；被告某进出口公司(抵押人)与原告(抵押权人)签订《房地产抵押合同》，约定被告某进出口公司将其所有的若干套房产抵押给原告，约定抵押担保范围为：某饭店管理公司在租赁合同项下对原告负有的一切债务，包括但不限于租金、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用(如律师费等)等，该合同第10.5条约定：在抵押权人实现抵押权时，无论抵押权人对抵押人和承租人的债权是否设定有其他担保(包括物权担保和保证)，均不影响抵押权人实现抵押权的权利。抵押权人有权自行选择实现担保的种类、方法和顺序。5月5日，上述房产均办理了不动产抵押登记，原告被登记为抵押权人。后原告已向被告某饭店管理公司放款，被告某饭店管理公司支付了手续费、保证金及部分租金等。

本案系再审查回重审案件。在原审中，原告向法院提供了一份《资产评估报告书》，载明评估机构为第三人某财税管理合伙企业，委托方为被告某饭店管理公司，评估结论为：确定截至评估基准日2019年4月1日，被告某饭店管理公司拟融资租赁委评的固定资产的评估值为33533200元，评估报告中包含上述《融资租赁合同(售后回租)》约定的租赁设备。

2021年5月，被告某进出口公司向财政部门举报第三人就案涉租赁物开展评估业务并涉嫌出具虚假评估报告等，财政部门对此开展调查核实。第三人于2021年7月9日登报发布公开声明，否认曾接受委托和出具上述资产评估报告。因案涉租赁物的真实性存疑，该案被发回重审。

在本案中，原告陈述：被告某饭店管理公司并未向原告提交原始购买租赁

物的合同原件及发票；公司区域总监对案涉租赁物进行了现场考察，根据公司租赁物审核制度要求，若能提供第三方权威机构出具的资产评估报告，可无须提供租赁物照片及发票，故当时仅要求某饭店管理公司出具资产评估报告。被告某进出口公司辩称，原告以融资租赁为名行民间借贷之实，应认定融资租赁合同无效，进而抵押合同亦无效。其提供担保是为融资租赁法律关系，为借款法律关系提供担保因欠缺真实意思表示而不成立，且加大了风险，故其不应承担担保责任。

另查明，被告某饭店管理公司已被法院裁定受理破产清算申请。

【案件焦点】

1. 某融资租赁公司展业依据的《资产评估报告书》被证伪后的法律关系认定；2. 融资租赁法律关系被否定后抵押合同的效力认定。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：因第三人否认出具案涉《资产评估报告书》，而原告并未提供其他任何租赁物相关所有权证明，亦未提供已对租赁物做过特定标识、实物检视、采取实地拍照或办理交接手续等相关证据，《所有权转移确认书》无法作为证明案涉租赁物真实存在的直接证据。作为专业的融资租赁公司，原告未尽上述审查义务，显然不合常理。故本院难以认定案涉租赁物客观存在且具有特定化。融资租赁合同属于以融物的方式实现融资，应当具有融资和融物的双重特征，而本案属于以融资租赁之名行借贷之实，原告与被告某饭店管理公司之间成立借款合同关系。因尚无证据表明原告存在以违规放贷为主要业务或利润来源等违法情形，故双方之间的借款合同关系合法有效。

对于被告某进出口公司应否承担抵押担保责任，法院认为，原告与被告某进出口公司签订的《房地产抵押合同》系当事人真实意思表示，未违反法律的强制性规定，依法成立并有效。对合同的定性不影响担保责任范围，租赁物不存在亦不影响某进出口公司承担担保责任。本案从融资租赁合同下的租金之债

变更为借贷关系下的本息之债，某进出口公司的担保风险并无不同。融资租赁合同中的租金系由出租人的融资成本及合理利润构成，与借款合同中的本息无实际区别。而且，根据双方签订的《房地产抵押合同》第10.5条的约定，即便租赁物真实存在，某饭店管理公司逾期不履行合同约定的付款义务，原告也可以根据自身利益最大化，选择不对租赁物折价、拍卖变卖的价款优先受偿，而是要求实现对某进出口公司的抵押权。某进出口公司在签订合同时对此就应明知，因此，租赁物不存在并不增加其担保风险。

综上，上海市浦东新区人民法院判决如下：

一、确认原告对被告某饭店管理公司享有借款本金、相应利息及律师费的破产债权；

二、若被告某饭店管理公司未履行上述还款义务，原告有权就被告某进出口公司名下的若干不动产行使抵押权，对拍卖、变卖所得价款优先受偿；

三、被告茹某对被告某饭店管理公司的上述还款义务承担连带保证责任。被告某进出口公司不服一审判决，提出上诉，上海金融法院经审理判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的主要问题在于，融资租赁合同关系因租赁物不真实而被认定为借款合同关系后，抵押人为融资租赁合同项下债务履行提供的附属抵押担保效力如何认定。

一、附属抵押合同效力应依据实际构成的法律关系效力认定

《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二款规定：“对名为融资租赁合同，但实际不构成融资租赁法律关系的，人民法院应按照其实际构成的法律关系处理。”据此，融资租赁合同性质的否定并不必然导致双方之间的实际法律关系无效，而是应当依据民法典及相关司法解释的规定，对双方之间实际构成的法律关系效力进行认定。本案中，原告在开展融资租赁业务的过程中虽有不规范，导致双方之间的法律关系被认定为借款合同关系，但对于双方之间的借款合同，并无证据表明其存在以违规放贷

为主要业务或利润来源等违法情形，未违反法律、行政法规的强制性规定，故双方之间的借款合同关系合法有效。

融资租赁合同关系因租赁物不真实而被否认后，附属抵押合同的效力应如何认定。根据民法典的相关规定，涉案抵押合同属于融资租赁合同的从合同，若融资租赁合同被认定为无效，则附属抵押合同亦为无效。然而，融资租赁合同的法律关系性质虽发生变更，合同主体之间的债权债务关系仍存在，对附属抵押合同的效力应当按照双方实际构成的法律关系效力进行认定。因此，附属抵押合同成为双方之间借款合同的从合同，其效力并不会因融资租赁合同关系的改变而发生变化。

二、租赁物不真实存在对抵押人担保责任的影响

在肯定附属抵押合同的效力后，需要分析考虑租赁物不真实存在是否对抵押人的抵押担保责任产生影响。

首先，主法律关系由融资租赁合同变更为借款合同后，抵押人的抵押担保范围有无变化。对此，应当结合抵押合同的约定、当事人的主张以及变更后法律关系的性质综合加以认定。本案中，原告自愿将利息调低至8.15%，低于融资租赁合同中约定的租金年化利率，且已将手续费等费用共计200万元从本金中扣除，因此抵押人某进出口公司担保的债务金额并未高于其签订《房地产抵押合同》时的合理预期，不存在担保范围增大的情况。本案从融资租赁合同下的租金之债变更为借贷关系下的本息之债，某进出口公司的担保风险并无不同。

其次，租赁物不存在是否增加抵押人的抵押担保风险。因为在融资租赁合同关系特别是售后回租模式下，租赁物当然地具有为融资租赁合同项下债务履行提供担保的物权属性，而租赁物不真实存在导致抵押人的抵押物增加了被直接行权的风险。对此，也应当依据双方之间的抵押合同的约定来加以分析。虽然民法典第三百九十二条规定了债务人的自物抵押应当优先偿还债务，但是在双方另有约定的情况下，仍应依照双方之间的约定来确定。本案中，抵押合同中未明确约定抵押人提供的抵押须以债务人提供的租赁物抵押为前提条件，反而明确约定了抵押权人有权选择不对租赁物折价、拍卖变卖，而是直接要求实

现对被告某进出口公司的抵押权。可见，某进出口公司在签订抵押合同时即明知原告在实现抵押担保时有权自行选择实现担保的种类、方法和顺序，因此并未超出当时可以预见的合理范围。

最后，需考虑出租人作为抵押权人对租赁物不真实存在是否具有故意或重大过失。如果出租人和承租人双方通谋故意以虚构租赁物的方式签订融资租赁合同，而抵押人对此并不知晓，仍以为融资租赁合同提供担保的意思订立抵押合同，则该种情形下，出租人的抵押权是否受到影响不无疑问。然而本案中并不存在该种情形，出租人用于确定租赁物的《资产评估报告书》系由承租人提供，出租人根据自身内部管理制度未进行现场调查，尚不构成故意或重大过失，也无证据显示出租人对租赁物的不真实具有其他过错情形，故出租人的抵押权不应受到限制，抵押人仍应按照抵押合同约定承担抵押担保责任。

因此，法律关系定性不会影响被担保债务的统一性，在无其他合同无效的情况下，主合同依然有效，担保人不能仅以法律关系定性发生变化为由要求免除已方责任，对于主合同项下的债务依然需要继续承担担保责任。

编写人：上海市浦东新区人民法院 俞砾 孙猛

融资租赁合同纠纷中承租人 未按约定方式还款、改装车辆构成违约

—— 罗某诉某融资租赁公司融资租赁合同案